

## **RESUMEN TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL: EXAMEN**

### **INTRODUCCIÓN**

#### **I. ACTORES DE LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL.**

Son, principalmente:

- 1) **Las Organizaciones Internacionales:** Lo que tratan de hacer es poner de acuerdo a los países mediante normas de conflicto. De ese modo, sin tener que renunciar a uno u otro principio, los gobiernos se ponen de acuerdo para, en ciertos casos, renunciar a tal o cual principio.

En este contexto, tenemos dos grandes actores:

- a. **La OCDE:** Organismo integrado por los países más desarrollados, que tiene por objeto la generación de políticas de gobierno adelantadas. Dentro de la OCDE hay un departamento de tributación internacional que se encarga de generar un modelo de Convenio de Doble Tributación Internacional (CDTI).

Si bien el modelo de la OCDE es muy simple, tiene una serie de documentos interpretativos, respecto de los cuales cada país realiza sus distintas reservas.

La OCDE también regula los BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*), que son casos en los cuales las empresas hacen uso de mecanismos tendientes a reducir su base imponible, y a trasladar a países que tienen bajo nivel de tributación las utilidades de la misma empresa.

Uno de los grandes problemas que tiene el modelo de la OCDE es que a veces ha producido casos de doble no tributación, por lo cual este es uno de los desafíos actuales de la OCDE, evitar la evasión fiscal.

- b. **La ONU:** La cual tiene su propio modelo de convenio.

- 2) **Los Gobiernos:** En este contexto, la causa de la tributación internacional es la existencia de dos o más gobiernos con traslapes de sus principios de tributación.
- 3) **Los Asesores Tributarios:** Su interés suele estar relacionado con el de las multinacionales.
- 4) **Las Multinacionales:** Uno de los fenómenos actuales es que, en virtud de la globalización, las grandes compañías son las que dictaminan el marco legal tributario, ya que los gobiernos dependen de las mismas para su desarrollo. Por ejemplo, en Europa, como todo el mercado está alineado, un fondo de inversiones puede trasladarse rápidamente de una jurisdicción a otra. Por eso los países deben competir por atraer inversiones relevantes mediante la reducción o exención de impuestos. Esto provoca que las multinacionales se conviertan en verdaderos colegisladores.

*Ejemplo Práctico:* Starbucks UK tiene un crédito con Starbucks EE.UU., y no paga renta sobre fuente extranjera. También tenía una sociedad en Suiza que compraba los granos de café y los vendía a todas las sociedades. También hay un pago de regalía a Holanda, el cual se gravaba con una tasa más baja. El resultado de esto es que Starbucks UK por un periodo de 15 años tuviera pérdidas tributarias.

#### **II. ASPECTOS GENERALES DE LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL.**

1. **La Aplicación Territorial del Impuesto:** Las leyes solamente son susceptibles de ejecución en el territorio del Estado de cuyo orden jurídico forman parte. Teóricamente, todos los Estados pueden hacer

tributar hechos acaecidos en cualquier parte del mundo, pero debe existir un factor de conexión con dicho Estado. Estos factores son: (i) residencia, (ii) domicilio, (iii) nacionalidad, (iv) fuente, entre otros. El problema es que puede ser muy difícil perseguir por parte del Estado a un sujeto que se encuentra ubicado en otro.

La conexión que tienen los Estados con un individuo pueden ser de grandes tipos:

- 1) **Personal:** Consiste en la residencia de los sujetos pasivos y establece una responsabilidad plena o ilimitada.
- 2) **Económica:** Se refiere a los intereses económicos (principio de la fuente) y establece una responsabilidad limitada.

La mayoría de los países aplica ambos principios, entre ellos Chile.

**2. La Legislación Chilena:** Encontramos varias normas que se refieren al problema de la extensión de la ley, las cuales pueden agruparse en tres grandes categorías:

- 1) **Normas Generales de Atribución:** La regla general está contenida en el **Art. 3, inc. 1 LIR** que señala que: *“Salvo disposición en contrario de la presente ley, toda persona domiciliada o residente en Chile, pagará impuestos sobre sus rentas de cualquier origen, sea que la fuente de entradas esté situada dentro del país o fuera de él, y las personas no residentes en Chile estarán sujetas a impuesto sobre sus rentas cuya fuente esté dentro del país”*.

Este artículo señala el factor personal por definición, porque parte indicando que las personas domiciliadas o residentes en Chile pagan impuestos en dicho país por las rentas de cualquier fuente. Pero, a su vez, genera un factor económico, ya que señala que los no residentes pagan impuestos sobre rentas de fuente chilena.

Sin perjuicio de lo anterior, el **Art. 3, inc. 2 LIR** señala un tercer factor de relevancia, el cual es la nacionalidad, la cual genera una franquicia para los extranjeros, ya que señala que: *“Con todo, el extranjero que constituya domicilio o residencia en el país, durante los tres primeros años contados desde su ingreso a Chile sólo estará afecto a los impuestos que gravan las rentas obtenidas de fuentes chilenas. Este plazo podrá ser prorrogado por el Director Regional en casos calificados. A contar del vencimiento de dicho plazo o de sus prórrogas, se aplicará, en todo caso, lo dispuesto en el inciso primero”*.

Otra norma general de atribución se encuentra en el **Art. 12 LIR** que establece como se computan las rentas de fuente extranjera que tiene un domiciliado o residente en Chile. Este artículo señala que las rentas de fuente extranjera liquidas se computan cuando sean percibidas. Esto tiene dos excepciones:

- a. **En el caso de las agencias u otros establecimientos permanentes en el exterior:** Un establecimiento permanente es un establecimiento que tiene una sociedad extranjera sin personalidad jurídica propia.
- b. **En el caso de los CFC (Controll Foreign Corporations) del Art. 41 G LIR:** Son sociedades controladas por un residente o domiciliado en Chile.

En ambos casos las rentas de fuente extranjera se computan cuando estén devengadas o percibidas, según que ocurra primero.

- 2) **Normas Complementarias relativas al concepto de Domicilio, Residencia y Fuente:**

- a. **Domicilio (Art. 59 CC):** *“Residencia acompañada real o presuntivamente del ánimo de permanecer en el lugar”*. Por tanto, tiene una parte objetiva consiste en la residencia física y una parte subjetiva consistente en el ánimo de permanencia.

Otra norma interesante es el **Art. 62 CC**, ya que señala que el domicilio no se muda por el hecho de residir un individuo “largo tiempo” en otra parte, conservando “su familia y el asiento principal de sus negocios en el domicilio anterior”. En este contexto, el SII ha señalado que ese “conservar los negocios en Chile” implica una preocupación permanente.

- b. **Residencia (Art. 8 N°8 CT):** *“Presencia física en el país por un plazo superior a 6 meses en un año calendario o por 2 años tributarios consecutivos”*. El problema es que el Código no dice nada respecto de las sociedades, pero en general se entiende que tienen domicilio o residencia en el lugar donde fueron constituidas.

- c. **Fuente (Art. 10 LIR):** Son rentas de fuente chilena las que provengan de:

- i. **Bienes situados en el país.**
- ii. **Actividades desarrolladas en Chile**
- iii. **Las regalías, los derechos por el uso de marcas y otras prestaciones análogas derivadas de la explotación en Chile de la propiedad industrial o intelectual.**
- iv. **La enajenación de sociedades extranjeros en el extranjero por personas no domiciliadas o residentes en Chile, las cuales posean activos subyacentes en Chile.**
- v. **Bonos emitidos en Chile por contribuyentes domiciliados o residentes en Chile.**
- vi. **Los intereses de cualquier operación de crédito en dinero si el deudor esta domiciliado o es residente en Chile.**

### 3) Normas para Evitar la Doble Tributación Internacional.

**3. La Doble Tributación Internacional:** Como cada Estado establece de manera soberana los criterios que definen su propio poder tributario puede ocurrir que una misma persona sufra imposición en más de un Estado por una misma renta o capital. Esto ocurre especialmente cuando dos Estados adoptan criterios diferentes para la definición del poder tributario o tienen, en el plano jurídico, un concepto diferente de un mismo principio.

*Ejemplo Práctico:* Un residente en México recibe una renta pagada en Brasil por servicios prestados en Argentina. Argentina cobrará impuestos por el principio de la fuente; Brasil lo hará invocando el mismo principio, ya que, de acuerdo a su legislación nacional, se considera renta de fuente brasileña cuando el pagador esta en Brasil. Y dado que México aplica el principio de la residencia, también cobrará impuestos. Y si, además el residente mexicano fuera de nacionalidad estadounidense, tendremos una hipótesis cuádruple porque EE.UU. aplica el principio de nacionalidad para cobrar impuestos.

Las medidas para evitar la doble tributación internacional pueden ser:

#### 1) Según su Fuente:

- a. **Unilaterales:** Medidas que adoptan los Estados por sí mismos, como el **Art. 3, inc. 2 LIR**.

- b. **Convencionales:** Medidas que adoptan los Estados mediante convenios para evitar la doble tributación. Puede ser:
  - i. **Bilaterales:** Entre dos Estados.
  - ii. **Multilaterales:** Entre varios Estados.

2) **Según el Método:**

- a. **De Exención:** Implica que se produce el hecho gravado pero el legislador decide no aplicar el impuesto. La mayoría de los convenios son de esta clase, y así fue el Convenio con Argentina inspirado en el Pacto Andino.
- b. **De Crédito:** Implica un descuento que se hace en el monto total a pagar de impuesto. Chile antes de firmar convenios ya había incorporado normas unilaterales en 1994 que siguen este criterio. Esto se encuentra en el **Art. 41 A LIR**, complementado por el **Art. 41 C LIR** en 1997.

**III. MEDIDAS INTERNAS ADOPTADAS POR CHILE PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL.**

Principalmente encontramos:

- 1) **Art. 5 CT:** El cual señala que: *“Se faculta al Presidente de la República para dictar normas que eviten la doble tributación internacional o que eliminen o disminuyan sus efectos”*. Esto es muy limitado por el principio de reserva legal en la condonación de impuestos.
- 2) **Art. 3 Ley N° 16.271 sobre Herencias y Donaciones:** El impuesto pagado en el extranjero sobre bienes de una sucesión servirá de crédito contra el impuesto en Chile, pero el impuesto que se pague en Chile no podrá ser inferior al que habría correspondido si se hubieran considerado solo los bienes situados en Chile.
- 3) **Art. 41 A LIR:** Establece como funciona el mecanismo de normas unilaterales respecto de países con los cuales no se tienen convenios para evitar la doble tributación internacional.
- 4) **Art. 41 C LIR:** Establece cómo funciona el mecanismo respecto de países con los cuales se tienen convenios para evitar la doble tributación internacional.
- 5) **Leyes N° 20.780 y 20.899, y Circular N°48 de 2016:** Reformas Tributarias.

1. **Reglas internas aplicables cuando no existe un CDTI (Art. 41 A LIR):** Este artículo señala principalmente cómo funciona el sistema de crédito para evitar la doble tributación internacional. Esto porque el Fisco no permite utilizar como crédito todo el impuesto pagado en el extranjero.

**1.1. Conceptos Clave:**

- 1) **El Crédito Total Disponible (CTD):** *“Cantidad de crédito que se puede imputar en Chile”*. Esto se da porque puede ser que un mismo contribuyente reciba rentas de distintos países y respecto de algunos hayan tratados de doble tributación, mientras que respecto de otros no haya tales tratados. Por ello habrá que ir determinando el crédito total renta por renta. Por regla general, dicho crédito es imputable contra el impuesto de 1era Categoría.
- 2) **Renta Neta de Fuente Extranjera (RENFE):** *“Renta o utilidad obtenida en el extranjero, menos los gastos, más los impuestos pagados en el extranjero”*. Esto implica que hay que determinar cuál

es la renta de fuente extranjera. Los gastos son aquellos que debieron hacerse en Chile para obtener dicha renta.

*Ejemplo Práctico:* Sociedad en Chile tiene 100 de utilidades y hay un impuesto de 24 por 1era Categoría, pero para calcular el global complementario se debe tomar en consideración lo pagado en 1era Categoría porque la renta fue de 100, no de 76. Por ello el impuesto pagado en el extranjero es parte de la renta, porque lo pagado fue efectivamente ganado por el contribuyente.

La RENFE es importante porque el crédito que da el Fisco de Chile es equivalente a la cantidad menor entre el impuesto pagado en el extranjero y el 32% de la RENFE.

## 1.2. Requisitos para utilizar el impuesto soportado en el extranjero como crédito fiscal:

- 1) **Inscripción del contribuyente en el Registro de Inversiones en el Extranjero del SII:** Este es un registro electrónico donde al no inscribirse se pierde el derecho a utilizar como crédito el impuesto pagado en el extranjero en ese ejercicio. Se puede inscribir hasta el cierre del ejercicio (31 de diciembre).
- 2) **El impuesto pagado en el extranjero debe ser un impuesto a la renta similar al establecido en la LIR:** Una cosa interesante es que se admite el Tax Sparing que es un crédito con el impuesto ahorrado en el extranjero, es decir, que si el Fisco del país extranjero dio un crédito para pagar los impuestos en el país extranjero, ese crédito se puede utilizar para pagar el impuesto en Chile. *Ejemplo Práctico:* Argentina da un crédito contra el impuesto corporativo que se debe pagar en Argentina por realizar una actividad. Este crédito es reconocido por el Fisco de Chile, es decir, se puede pagar el impuesto chileno con el crédito argentino. En este caso, el **Art. 41 A LIR** señala que, si quedara un remanente, no se podrá pedir la devolución de este.
- 3) **Se deben acreditar fehacientemente los impuestos pagados en el extranjero:** Esto se hace mediante un certificado oficial emitido por el país extranjero o mediante el comprobante de pago. Estos certificados deben señalar el año, los impuestos de que se trata, la identificación del contribuyente, etc.
- 4) **Debe tratarse de rentas que se afecten con impuesto de 1era Categoría, provenientes de:**
  - a. **Dividendos.**
  - b. **Retiros de utilidades.**
  - c. **Rentas percibidas o devengadas provenientes de agencias u otros establecimientos permanentes en el extranjero:** Los establecimientos permanentes son importantes porque anulan cualquier beneficio que tengan las sociedades extranjeras establecidos en el CDTI. Además, cuando una empresa extranjera tiene un establecimiento permanente en Chile dicho establecimiento permanente queda obligado a cumplir todas las obligaciones tributarias que deben cumplir los contribuyentes domiciliados o residentes en Chile.
  - d. **Rentas pasivas (Art. 41 G LIR):** Son las rentas que se obtiene de una sociedad en el extranjero que controla un domiciliado o residente en Chile (CFC).
  - e. **Rentas percibidas por el uso de marcas, patentes, fórmulas, asesorías técnicas y otras prestaciones similares que hayan sido gravadas en el extranjero.**

Los últimos tres casos solo se pueden usar contra el impuesto de 1era Categoría. Es decir, si por cualquier razón el crédito sobra solo puede arrastrarse a ejercicios posteriores. En el caso de los

dividendos y retiros de utilidades, se puede utilizar contra el impuesto de 1era Categoría o contra los impuestos finales, es decir, en caso que quede un remanente después de imputarlo a 1era Categoría, puede imputarse contra Global Complementario. Si aun después de su uso quedará un remanente, se pierde. Es decir, no se puede arrastrar.

- 5) **El CTD equivale a la suma menor entre el impuesto pagado o retenido en el exterior y el 32% de la RENFE.**

**2. Reglas internas aplicables cuando existe un CDTI (Art. 41 C y 74 N°4 LIR):** Se siguen las mismas reglas generales del **Art. 41 A LIR**, pero con algunas diferencias, que son:

- 1) **El CTD equivale a la suma menor entre el impuesto pagado o retenido en el exterior y el 35% de la RENFE, salvo que el “beneficiario efectivo” de la renta no tenga domicilio en Chile:** Cuando se habla de **Beneficiario Efectivo** lo que se quiere evitar es el “*treaty shopping*”, que es básicamente “vitriñar” entre las distintas jurisdicciones cuál es la más favorable a la luz de los tratados. Por eso, podría ser que una persona en apariencia tenga domicilio o residencia en Chile, pero en realidad el beneficiario efectivo, a quien le corresponde finalmente la renta, no este domiciliado o residente en Chile. Esto es básicamente una norma anti elusión especial. La sanción es volver a las normas generales.
- 2) **Las rentas que dan derecho a crédito son las que se establecen en cada CDTI.**
- 3) **La retención por los pagos o remesas que se efectúen al exterior y que están afectas con impuesto adicional no es aplicable cuando la renta se beneficia con alguna disposición del CDTI, siempre que el beneficiario de la renta acredite con un certificado su residencia en el país respectivo y declare que no tiene un establecimiento permanente en Chile.**

### **LOS CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL**

Son una verdadera fuente del derecho tributario, de hecho, de acuerdo a la Constitución, tienen “primacía sobre la ley ordinaria” de los Estados. Deben ser aprobados por el Congreso y promulgados por el Presidente de la República.

**1. Métodos utilizados en los convenios para evitar la doble tributación:** Consisten en establecer de antemano que una determinada renta es imponible solamente en un “Estado Contratante”, o bien, que siendo imponible en ambos, un Estado se obliga a dar crédito por el impuesto pagado en el otro Estado. Los CDTI cambian el principio de la fuente por el del domicilio o residencia.

**2. Fines de los convenios:** El fin principal es evitar la doble tributación internacional, pero además persiguen otros fines o propósitos secundarios:

- 1) **Proteger al contribuyente y dar estabilidad a las normas tributarias:** Esto tiene que ver con el hecho de que las normas de los convenios tienen primacía sobre las normas internas de los Estados.
- 2) **Prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de tratamiento entre nacionales y extranjeros.**
- 3) **Promover la inversión privada en los países en desarrollo.**
- 4) **Fomentar la transferencia de tecnología.**
- 5) **Combatir la evasión y elusión de impuestos con medidas como el intercambio de información:** En los CDTI se establecen normas que obligan a los países a intercambiar información. Se obliga a

los SII de los países a que intercambien información. Esto es importante para evitar casos de elusión y evasión.

### **3. Inconvenientes de los convenios:**

- 1) **Los países en desarrollo generalmente “entregan” más que los países desarrollados:** Los países que más ganan con los convenios son los países desarrollados debido a que se impone el principio del domicilio o residencia del contribuyente, sin perjuicio de que el país en desarrollo, si bien no gana a nivel de tributación, gana por el intercambio tecnológico.
- 2) **Rigidez:** Dejar de cumplir un convenio es muy difícil.
- 3) **Desigualdad en las Negociaciones:** El país más poderoso tiene mayor capacidad de negociar y de imponer sus condiciones al país que tiene menos capacidad negociadora.

**4. Modelos de los Convenios:** Los modelos más utilizados en el mundo son los de la OCDE y de la ONU. Ambos se basan en los modelos desarrollados por la Liga de las Naciones entre los años 1927 y 1946.

**5. Efectos de los Convenios:** Tienen fuerza de ley, y en caso de conflicto con una ley nacional, el convenio prevalece sobre la ley interna. Ahora bien, es importante que **no tienen como finalidad crear impuestos o hechos gravados**, sino que tienen un efecto negativo, limitando, restringiendo o coartando los poderes tributarios de los Estados.

## **ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE)**

El estudio y problema de la doble tributación surge con fuerza luego de la 2da Guerra Mundial. A partir de ella, diversas organizaciones internacionales se han preocupado de considerar y ofrecer soluciones para evitar o atenuar la doble tributación internacional.

En este contexto surge la OCDE, que es una organización continuadora de la Organización para la Cooperación Económica Europea (OEEC), creada en 1947 para administrar los fondos del Plan Marshall para la reconstrucción de Europa después de la 2da Guerra Mundial.

Existe formalmente desde 1960 con 20 miembros originales. Tiene su sede en París y los países miembros representan el 72% del PIB global.

**1. Concepto:** *“Foro en el cual los gobiernos de los países miembros comparan experiencias de políticas públicas, buscan respuestas a problemas comunes, identifican buenas prácticas y coordinan políticas internas e internacionales”.*

Para poder pertenecer a este club se deben compartir dos principios: (i) ser un país democrático y (ii) tener una economía de mercado. Si alguno de los países miembros pierde esta característica el país puede ser sacado de la OCDE.

### **2. Funciones de la OCDE:**

- 1) **Realiza estudios e investigaciones:** El principal objetivo de la OCDE es proponer políticas públicas económicas que los países deberían adoptar. En ese sentido, hay un permanente seguimiento de las tendencias económicas, haciendo proyecciones de corto y mediano plazo. La OCDE difunde su trabajo a través de la publicación de aproximadamente 250 títulos al año.
- 2) **Evaluaciones entre pares (peer reviews):** Es el elemento más distintivo que tiene como organización internacional. Cada año los Estados son citados a la sede de la OCDE y los demás

Estados miembros hacen un examen donde se cuenta como se están implementando las distintas políticas públicas. Los que evalúan son los pares, quienes dan recomendaciones.

- 3) **Desarrollo de estándares o reglas para la cooperación internacional:** Detección de desafíos que enfrenta la economía global o los estándares de las políticas públicas en ciertas áreas. Los acuerdos pueden quedar plasmados en: (i) acuerdos internacionales, (ii) decisiones del Consejo, (iii) recomendaciones del Consejo y (iv) pautas o directrices. Los primeros dos son vinculantes y obligatorios para los Estados miembros.
- 4) **Recopilación de estadísticas y de información económica y social:** Se trata de información comparable entre los miembros. Esto implica que todos los países miembros deben ajustar sus informaciones al modelo fijado por la OCDE. Además, administra el programa PISA (*Programme for International Students Assessment*) y los resultados de estas pruebas son utilizados ampliamente como indicador de calidad entre países.

3. **Funcionamiento de la OCDE:** Tiene un órgano superior de gobierno que es el Consejo, compuesto por un representante permanente de cada país miembro, más un representante de la UE. Es dirigido por un Secretario General.

4. **Patrimonio Legal de la OCDE:** “*Conjunto de instrumentos legales de la organización*”. Todo país que desee ingresar a la OCDE debe suscribir o aceptar este patrimonio legal.

5. **¿Qué significa ser miembro de la OCDE?:** Significa básicamente adquirir ciertas obligaciones formales, como participar o estar presente en todos los órganos a los que se accede automáticamente como miembro de la OCDE. Es un “certificado” de que se aplican políticas económicas acertadas en el país, al menos en abstracto. No hay sanción para incumplimientos, pero sí presión de los demás países en caso de no aceptarse una recomendación.

6. **El ingreso de Chile a la OCDE:** En 2007 se hace una invitación formal a Chile, Eslovenia, Estonia, Israel y Rusia a iniciar conversaciones para convertirse en miembros de la OCDE, pidiendo a Chile que lleve antecedentes para verificar que cumple con los criterios del organismo, lo que se denomina como “hoja de ruta”.

Para que Chile pudiera ingresar a la OCDE se exigieron cuatro reformas:

- 1) **Modificación del Gobierno Corporativo de CODELCO:** La cual se hizo por la Ley N° 20.392.
- 2) **Que el SII pudiera intercambiar información sobre cuentas corrientes bancarias:** Que se hizo mediante la Ley N° 20.406 elimina el secreto bancario. Fue la norma más discutida de todas.
- 3) **Reforma al gobierno corporativo de las sociedades privadas:** Que se hizo mediante la Ley N° 20.398.
- 4) **Responsabilidad penal de las personas jurídicas por actos de soborno a empleados públicos:** La cual se hizo por la Ley N° 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

## EL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL DE LA OCDE (CDTI)

### I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

La génesis del modelo de Europa en gran medida viene porque después de las guerras mundiales se empezaron a liberalizar las fronteras y se generó un intercambio fluido de bienes y personas. Ante este escenario, la doble tributación atentaba contra la idea de igualdad de trato, y podía influir en la decisión de inversión o trabajo. En este contexto, la Liga de las Naciones fue la primera que empezó a preocuparse de forma sistemática de este tema, viendo cómo y dónde se producía esta doble tributación, y los mecanismos para evitarla.

Así se creó el Modelo México en 1943 que se centra en el principio de la fuente, dándole preponderancia a este país. Luego se creó el Modelo Londres de 1946 que le dio preponderancia al principio de la residencia.

La OEEC, que posteriormente se amplió formando la OCDE, tomaron el trabajo de la Liga de las Naciones, pero tomando el modelo de Londres. De ahí en 1963 se crea un borrador de modelo que fue publicado en 1977.

El modelo de la OCDE se estructura en dos grandes principios. En primer lugar, que el país de la residencia se somete al sistema de crédito o exención. En segundo lugar, se limita la fuente.

## II. FUNDAMENTOS DEL CDTI.

### 1. Fundamentos Comunes:

- 1) **Equidad y Justicia Tributaria:** Se suele distinguir entre justicia o equidad horizontal y vertical:
  - a. **Justicia Horizontal:** Es la habilidad para pagar por recibir un ingreso, siendo lo justo y razonable.
  - b. **Justicia Vertical:** Se relaciona con las tasas progresivas sobre la retribución que uno hace en función de la riqueza acumulada.

El sistema tiene que compatibilizar ambos aspectos.

- 2) **Neutralidad y Eficiencia:** La idea es que las decisiones de inversión no estén vinculadas a un factor tributario, preferentemente siendo neutro. Los factores de productividad no debieran estar incluidos por el sistema tributario. La idea es que la movilidad de una empresa se deba a un criterio propio de los factores del mercado y no a factores tributarios.
- 3) **Promoción del Libre Comercio y de las Inversiones:** La idea es que, al eliminar la doble tributación, haya menos barreras para el comercio internacional, facilitándolo.
- 4) **Prevención de la Evasión Tributaria:** Dentro de los objetivos de los CDTI está también el evitar la evasión, con una cláusula de intercambio de información entre los países.
- 5) **Reciprocidad:** Se empieza a notar desde el inicio, ya que se tiene que renunciar a ciertas cosas por ambos países.

### 2. Fundamentos Normativos:

- 1) **Jurisdicción Tributaria de los Estados:** El Estado tiene una jurisdicción para imponer impuestos sobre los contribuyentes, buscándose un cierto factor de conexión, como el domicilio, la residencia, la nacionalidad, el centro de negocios, el lugar de constitución, la fuente, el lugar de la administración o casa matriz, etc.
- 2) **Conflictos en la Aflicción de los Factores de Conexión:** Puede ser que se superpongan, haciendo que dos Estados reclamen impuestos sobre una misma persona o renta:

- a. **Fuente vs Fuente:** Puede darse que sea en el comprador o en el vendedor, de modo que en ambos casos tributaria esta renta.
- b. **Residencia vs Residencia:** Puede ser que un país considere por residencia la ubicación física, mientras que otro exija criterios distintos para constituir residencia.
- c. **Fuente vs Residencia:** Puede haber situaciones en las cuales un país adopta un criterio de residencia gravando las rentas de fuente mundial y otro grava las rentas de fuente del país en particular, habiendo una clásica situación de doble tributación internacional.
- d. **Calificación Jurídica:** Cuando no conversan los conceptos jurídicos de un país con otro, por ejemplo, qué se considera como regalía o dividendo.
- e. **Entidades:** Puede ser que un país considere una entidad de una forma y otro de otra forma distinta. *Ejemplo: EE.UU. consideraba una entidad inglesa como transparente, por lo que tributaba tanto en Inglaterra como en EE.UU.*
- f. **Inconsistencias entre Sistemas Tributarios:** Un buen ejemplo de esto son las inconsistencias en los tiempos en la declaración y pago de los impuestos, ya que en Chile se declara en abril y en otros países es en julio. Además, puede ocurrir que en un país se tribute sobre base devengada y en el otro sobre base percibida.

### 3) Doble Tributación Jurídica vs Doble Tributación Económica:

- a. **Jurídica:** Es la igualdad en todos los elementos del impuesto: sujeto, hecho gravado, base imponible y un mismo periodo tributario.
- b. **Económica:** Se refiere al caso en que falla el elemento del sujeto, dándose un impuesto con la misma base imponible y hecho gravado en cabezas distintas.

El modelo de la OCDE apunta a la doble tributación jurídica, por lo que el objetivo inmediato es esta, pero está presente la económica, ya que no se justifican cargas tributarias especialmente altas, aunque sean en sujetos y etapas distintos.

En Chile existe un caso dramático de esto sobre intereses, ya que, si se pagan a no domiciliados o residentes en Chile la tasa general es del 35%, pero ciertos créditos con instituciones financieras extranjeras están sujetos a una tasa preferente de un 4%, como medida para incentivar estos préstamos con instituciones confiables.

## III. ELEMENTOS CLAVE DE LOS CDTI.

### 1. Neutralidad en la Exportación e Importación de Capitales:

- 1) **Neutralidad en la Exportación:** Implica que para el economista nacional sea equivalentemente conveniente invertir en Chile como en el extranjero. Un país que quiere obtener una neutralidad en la exportación de capitales debe generar en los convenios que se reconozca el principio de la residencia porque si hubiere muchas concesiones el capital se quedaría en la fuente, dejando de tributar en la residencia. Junto con ello se aplicaría un método de crédito.
- 2) **Neutralidad en la Importación:** Implica que para el economista extranjero sea equivalentemente conveniente invertir en Chile como en el extranjero. Si el país se preocupara por esto buscaría que se tribute en fuente, porque en fuente se podría evitar la distorsión que se genera en residencia. Junto

con ello se aplicaría un método de exención de manera tal que no se distorsione el retorno a la residencia.

Es por ello que los intereses de los distintos países no siempre coinciden, ya que los países desarrollados son generalmente exportadores de capitales, mientras que los países en desarrollo son principalmente importadores de capitales.

## 2. Rentas Activas vs Rentas Pasivas:

- 1) **Renta Pasiva:** *“Aquella que se obtiene sin el desarrollo de una actividad”*. En este caso se aplica el principio de la residencia, ya que si tenemos una regalía todo el trabajo intelectual fue realizado en el país de la residencia.
- 2) **Renta Activa:** *“Aquella que está asociada al desarrollo de una actividad”*. En la medida que se desarrollen actividades en un país extranjero se entiende que hay legitimidad para gravar en fuente porque en fuente existe una institucionalidad que permite generar esa renta. Por eso, tratándose de rentas activas, el modelo reconoce que el Estado de la fuente puede imponer tributo sobre esa renta, otorgándose un crédito en residencia contra el cual imputar lo pagado en fuente.

## IV. MECANISMOS PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN.

Existen tres grandes principios en el CDTI:

- 1) **Jurisdicción Tributaria Exclusiva:** Siguiendo el modelo de la residencia, se impide al país de la fuente imponer tributación en fuente. *Ejemplo:* Regalías que solo tributan en fuente, lo mismo las ganancias de capital en la enajenación de acciones y valores, aunque en este caso Chile da vuelta esta cláusula, generando una jurisdicción tributaria ilimitada, también se cuentan acá las pensiones, lo que reciben los estudiantes, los beneficios empresariales o bussiness profits, etc.
- 2) **Jurisdicción Tributaria Compartida:** En este caso se permite la imposición tributaria en fuente, generándose una tributación compartida con residencia.
  - a. **Potestad tributaria ilimitada en el país de la fuente:** Implica que no hay límite en fuente para aplicar la tributación respectiva, aplicándose totalmente el derecho interno. En estos casos se aplica el método del crédito. *Ejemplo:* Explotación, tenencia y enajenación de bienes inmuebles, ganancias y premios de deportistas, rentas del sector privado, etc.
  - b. **Potestad tributaria limitada en el país de la fuente:** Se trata de ciertos casos en que el CDTI autoriza que se graven en fuente, pero con limitaciones. *Ejemplo:* Dividendos e intereses. En el caso de Chile, jamás se ha aceptado la cláusula de dividendos (cláusula Chile) porque se entiende que el modelo integrado no lo permite porque el impuesto corporativo suele ser mucho más alto en otros países de lo que es el impuesto adicional en Chile. Es así que la cláusula Chile permite a nuestro país gravar en fuente ilimitadamente los dividendos según su legislación interna siempre que el impuesto de 1era Categoría pueda ser utilizada como crédito contra el impuesto adicional.
- 3) **Mecanismo para atenuar la Doble Tributación:** Los CDTI hacen uso del método del crédito y de la exención. El **Art. 23 A CDTI** fija el modelo de la exención y el **Art. 23 B CDTI** fija el modelo del crédito. Cuando los países fijan el CDTI que utilizaran deben escoger alguno de estos dos artículos para que los rija, siendo principalmente escogido el **Art. 23 B**.

## V. OTRAS FINALIDADES DEL CDTI.

Tenemos:

- 1) **Evitar la Evasión Fiscal:** Mediante la transmisión de información entre los servicios de impuestos de los distintos países.
- 2) **Evitar la Discriminación entre Nacionales y Extranjeros.**
- 3) **Cláusula de la Nación más favorecida:** Si bien no está en el CDTI, si hay cierta práctica en los últimos años que cuando se negocia un CDTI se coloca una cláusula que dice que si un Estado le aplica un tratamiento más beneficioso a otro Estado, ese mismo tratamiento también se aplicará al Estado con el que existe esa cláusula. Su fuente está en un protocolo. Estas cláusulas suelen estar restringidas a ciertos elementos particulares, por eso usualmente el SII tiende a explicar estos conceptos mediante circulares, aclarando la aplicación en particular de la cláusula de la nación más favorecida en el caso concreto. Es por esto que es importante analizar los protocolos, porque pueden modificar o aclarar los señalado en un CDTI.

Tanto el intercambio de información como la no discriminación no están limitadas a los impuestos a la renta o al capital, sino que pueden usarse respecto de otros impuestos como el IVA. Por eso, son artículos que van más allá de los impuestos sobre los que se aplica el CDTI.

## VI. CONSIDERACIONES GENERALES DEL CDTI.

1. **Ámbito Personal (Art. 1 CDTI):** Se aplica respecto de los residentes de uno u ambos Estados.

El **Art. 4 N°1 CDTI** define que se entiende por residente, indicando que es *“aquel que es sujeto de impuestos en el país contratante”*, es decir, que es contribuyente, entendiéndose por impuesto el impuesto a la renta. Esto no aplica respecto de aquel que es sujeto a impuesto en el Estado contratante solo por rentas que son de fuente de dicho Estado.

El **Art. 4 N°2 CDTI** señala que, cuando, en virtud de las disposiciones del apartado 1, una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

- 1) **Dicha persona será considerada residente solamente del Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente solamente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales);**
- 2) **Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente solamente del Estado donde more;**
- 3) **Si morara en ambos Estados, o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente solamente del Estado del que sea nacional;**
- 4) **Si fuera nacional de ambos Estados, o no lo fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.**

*Caso Apple:* Irlanda tenía una APA con Apple que le permitía pagar menos impuestos en Irlanda. Ante ello la UE sancionó a Apple porque esta ayuda estatal estaba prohibida, ya que no cumplía con los requisitos fijados por la UE, ordenándole pagar una suma elevada correspondiente a los impuestos.

En relación al concepto mismo de **Residente**, el **Art. 4 CDTI** establece una serie de elementos que lo componen:

- 1) **Persona:** El **Art. 3 CDTI** lo define como: *“personas físicas, sociedades y cualquier otra agrupación de personas”*. Sin embargo, esta disposición es de aquellas que recibe la mayor cantidad de cambios en la negociación de los convenios, ya que, por ejemplo, en el CDTI con Canadá se incluyen los fideicomisos o *trust* dentro del concepto de persona.
- 2) **Contribuyente bajo derecho local:** Esa persona debe estar sujeta a impuestos en el Estado contratante.
- 3) **Factor de Conexión:** Esa persona debe pagar impuestos en dicho Estado en razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga.
- 4) **No aplica a aquel contribuyente que lo es solo en virtud del principio de la fuente:** Es decir, aquel que debe pagar impuestos en el Estado contratante exclusivamente por las rentas de fuente de ese Estado.

### 1.1. Casos Especiales:

- 1) **Sociedades Transparentes:** Es parecido al sistema atribuido chileno, en el sentido que la sociedad o estructura legal que obtiene la renta tributariamente no existe y se atribuyen esos beneficios o rentas al socio o accionista. Mediante el ejercicio de una opción en EE.UU., una sociedad puede ser reconocida como sociedad transparente, aplicando directamente impuestos en EE.UU. Esto generó un problema en Reino Unido, porque no reconocía la existencia de este sistema, por lo que aplicaba impuestos corporativos contra la sociedad ubicada en Inglaterra, lo que generó una disputa respecto a qué país debía dar crédito.
- 2) **Vehículos de Inversión Colectivos (Trust):** Estos también poseen una neutralidad, ya que el inversionista quiere que no se apliquen más impuestos sobre el vehículo, generándose problemas de si es o no residente. En Chile se aplica sobre los fondos de inversión, en los cuales la Ley Única de Fondos establece que, cuando se cumplen ciertas condiciones legales, los fondos no tributan con primera categoría, por lo cual se discute su carácter de residente en Chile.

El elemento común de estos dos casos es que el vehículo o plataforma legal de inversión desde un punto de vista fiscal se considera transparente, es decir, toda la utilidad que percibe se le atribuye directamente al inversionista que está detrás. *Ejemplo Práctico: Tenemos inversionistas chilenos que invierten en un vehículo de inversión que se encuentra en Brasil, el cual invierte en Perú. Como es transparente no es residente en Brasil, sino que solo pagaría impuestos en Chile. El problema es que en Perú podrían no reconocer el carácter de transparente de dicho vehículo, indicando que quien invirtió fue una sociedad brasileña. De ahí que lo mejor es definir en el CDTI como se tratarán los vehículos de inversión.*

2. **Ámbito Material:** Se refiere a qué impuestos se les aplica el CDTI. Por regla general, se aplica a impuestos a la renta y al patrimonio. Como Chile no tiene impuestos al patrimonio, solo se aplica a los impuestos a la renta, es decir, a los impuestos establecidos en la LIR. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, porque admite excepciones donde se aplica el CDTI respecto de otros impuestos:

- 1) **Cláusula de No Discriminación (Art. 24 N°7 CDTI):** Esta se aplica respecto de todos los impuestos y se refiere a que un extranjero no puede ser discriminado en el cobro de impuestos que se cobran al nacional.
- 2) **Cláusula de Intercambio de Información.**
- 3) **Cláusula de Asistencia en la Recaudación de Impuestos:** Chile no es muy proclive a incluir esta cláusula porque se deja a las reglas generales de los tribunales de justicia y el exequatur.

**3. Ámbito Territorial:** Se aplica en todo el territorio de los Estados contratantes, salvo las exclusiones expresamente establecidas. En Chile usualmente no se excluyen territorios, pero respecto de ciertos Estados que tienen territorios anexos puede llegar a darse.

**4. Ámbito Temporal:** En Chile los convenios deben ser ratificados por el Congreso (**Art. 54 N°1 CPR**). Hay dos etapas:

- 1) **Entrada en vigor:** Los CDTI exigen el intercambio de notificaciones para su entrada en vigor. Es decir, el CDTI una vez suscrito y ratificado, para poder entrar en vigor Chile debe notificar a su contraparte del cumplimiento de todas las exigencias según la ley doméstica para que entre en vigor. El CDTI entra en vigor a la fecha de la última notificación, entendiéndose de ese modo que cumplió con la regulación interna de ambos Estados. Esto no implica que el CDTI entra en vigencia, ya que tienen una fecha posterior de vigencia.
- 2) **Vigencia:** Debido a que suelen haber problemas en relación con el año tributario, en Chile se dice que entra en vigencia respecto de las rentas que se paguen, se abonen en cuenta, se pongan a disposición del extranjero o se contabilicen como gasto a partir del 1 de enero del año siguiente a su entrada en vigor. Es decir, el CDTI recién comienza a regir respecto de las rentas que se obtienen posteriormente al 1 de enero.

## VII. CASO BAYFINE CON HMRC.

**1. Los Hechos:** El 20 de julio de 2000 dos filiales del grupo Morgan Stanley constituidas en Reino Unido (Bayfine UK Products y Bayfine UK) entraron en contratos *forward* con filiales americanas del Bank of America (Irving Park y Mecklenburg Park). Los contratos se diseñaron de forma tal que se anulaban entre sí. Sin embargo, dado que no fueron pactados por el mismo contratante, una de las filiales obtendría una utilidad y la otra una pérdida por una suma equivalente.

A la fecha de vencimiento de los contratos (15 de agosto de 2000), Bayfine UK Products (BUKP) obtuvo una pérdida por 170 millones, cuya contrapartida fue una utilidad por idéntica suma de Bayfine UK (BUK).

Bajo el *The Check the Box Regulation* en USA, Baycliff DE eligió que su filial BUKP no fuese transparente desde la perspectiva impositiva, mientras que Bayfine DE hizo la elección contraria, de modo que BUK se consideró transparente fiscalmente.

A consecuencia de esto la pérdida no se reconoció en USA, pero sí la utilidad, quedando sujeta al impuesto corporativo allá. La pérdida obtenida por BUKP recibió en UK el tratamiento tributario de pérdida ajena al giro (*non-trading deficit*), siendo utilizada por varias empresas del grupo Morgan Stanley en UK conforme a las normas tributarias de consolidación de resultados del Grupo Empresarial. Quedó un remanente no utilizado que se arrastró a ejercicios futuros.

La utilidad generada por BUK constituyó una utilidad ajena al giro (*non-trading profit*) afecta al impuesto corporativo. En contra del impuesto a pagar en UK, BUK reclamó un crédito por los impuestos pagados en USA, invocando para estos efectos el CDTI existente entre ambos países, lo que anulaba el impuesto a pagar en UK.

El SII de UK (HMRC) objetó el crédito invocado por BUK, lo que provocó la judicialización del caso, siendo los principales puntos de discusión:

- 1) **El derecho a tax credit por los impuestos pagados en UK bajo las disposiciones del CDTI en ambos países.**

- 2) Si la conclusión es que no hay derecho a tax credit, si puede reclamarse el mismo bajo las normas unilaterales de UK.
- 3) Limitaciones al tax credit unilateral.

**2. Resolución de los Tribunales:** Una de las cuestiones que más se debatió fue cual era la fuente de esas rentas, ya que lo lógico es que debiera tributar en el país de la fuente por las utilidades corporativas. Pero con un poco de información se pudo aplicar la lógica de que cuando hay un beneficio empresarial por el **Art. 7 CDTI** queda gravado en el país de residencia de la empresa y por ello en EE.UU. se debía dar el crédito.

También se analizó el objeto del CDTI y se llegó a la conclusión de que cada país podía interpretar el Convenio, ya que no existía ningún órgano supranacional que determinara cómo debía interpretarse el convenio.

## VIII. INTERPRETACIÓN DE LOS CDTI.

**1. Aspectos Generales:** Los CDTI no están destinados a establecer obligaciones tributarias, a señalar hechos gravados.

### 1) Naturaleza de los CDTI:

- a. **Conflictos de Leyes:** No es la forma correcta de interpretar los CDTI como conflictos de leyes.
  - b. **Reglas de Distribución de la Jurisdicción Tributaria:** Este es el criterio que prima en los CDTI, es su idea marco.
  - c. **Hecho gravado está establecido en la regulación interna de los Estados:** En este contexto se dio un caso muy particular, que fue el conflicto entre el concepto de agencia que utiliza nuestra legislación y el concepto de establecimiento permanente utilizado por los CDTI. Para nuestra legislación, si bien no se define, una agencia es una persona natural o jurídica que actúa con poderes amplios de una persona jurídica extranjera, que lo habilita para actuar en nombre de ella en Chile. Para el CDTI un establecimiento permanente es una base fija de negocios, indicando ciertas presunciones donde existiría un establecimiento permanente. Así es como una asesoría que se presta por más de 180 días en un Estado contratante se entiende que es una agencia. El problema está en si estos conceptos pueden analogarse o son distintos. *Ejemplo Práctico: Geólogo que presta sus servicios en Chile, estando gravado con adicional de retención. Según el CDTI hay un EP en Chile, lo que autoriza al país de la fuente para gravar la renta sin limitación alguna. Si decimos que EP y agencia son lo mismo, debería pagar 1era categoría y adicional, lo que da una carga tributaria efectiva del 35%, mientras que si decimos que no es agencia solo corresponde aplicar un 20% de impuestos. El resultado es que si analogamos los conceptos estaríamos creando un hecho gravado.* El SII determinó que en este caso que, si bien hay un Establecimiento Permanente según el CDTI, lo que autoriza al cobro ilimitado, no hay agencia según el derecho interno, por lo que se aplica el impuesto del 20% y no del 35%.
- 2) **Aproximación a los CDTI:** Cuando se da un problema de doble tributación, el país puede interactuar con el CDTI mediante distintos criterios:
- a. **Principio de Subsidiariedad:** Dado que el derecho interno es el que establece los hechos gravados y el CDTI solo los restringe, el CDTI tiene una aplicación subsidiaria. Es decir,

primero se analiza si el hecho está gravado por la ley chilena y luego se ve que señala el CDTI. Este principio se aplica en Francia y parte de la doctrina alemana también la acoge. En opinión de la cátedra este es el principio correcto.

- b. **Principio de Supremacía:** Establece que el CDTI tiene supremacía sobre la ley interna.
- c. **Principio de Especialidad:** Establece que el CDTI es más especial que el derecho interno, por lo que prima sobre aquel.

### 3) Conclusión e Implementación de los CDTI:

- a. **Sistema Monista vs Sistema Dualista:** El sistema monista establece que el derecho internacional y el derecho interno son un mismo sistema, por lo que el tratado, una vez ratificado se cumple solo, no es necesaria una norma adicional para que sea aplicable. El sistema dualista dice que son sistemas distintos, por lo que una vez que el tratado ha sido ratificado, se requiere una ley interna que lo ponga en práctica. Inglaterra tiene un sistema dualista con una ley que ordena los tratados.
- b. **Treaty Override:** Es la facultad de reescribir los términos del CDTI de forma unilateral en virtud de la norma interna. Bajo un sistema dualista basta con modificar la ley que da aplicación al CDTI para poder modificar el mismo CDTI. En el sistema monista hay que modificar el CDTI mismo. La OCDE dice que se puede hacer un *treaty override*, pero siempre que este posibilite un mayor control de evasión. Ejemplo: Las CFC fueron un *treaty override* ya que era contrario a los CDTI. Hoy la OCDE tiene en los capítulos iniciales una autorización a las normas antielusivas que no son *treaty override*, legitimándolas. Es decir, están admitidas para evitar la doble no tributación.

En Chile se aplica el sistema monista. Se requiere de la ratificación en el Congreso para su promulgación (**Art. 54 N°1 CPR**). El TC tiene control de constitucionalidad preventivo (**Art. 93 N°1 CPR**) y represivo (**Art. 93 N°6 CPR**) sobre los tratados.

**2. Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados:** Se cuestiona la doctrina si los CDTI deben ser interpretados conforme a la Convención de Viena o no, entendiendo que no hay tribunal internacional que sea vinculante para ambos Estados en esta materia. En la práctica todos los autores tienen consenso que, si aplicaría dicha convención, ya que los CDTI cumplirán con su objetivo en la medida que haya una interpretación y entendimiento armónico de los mismos. Si cada país interpreta a su modo el CDTI se genera un fraccionamiento y se agudiza la doble tributación o se conduce a situaciones de doble no tributación.

#### 2.1. Regla General de Interpretación (Art. 31 C. Viena):

- 1) **Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin:**
  - a. **Buena Fe:** Lo que debe primar siempre es la buena fe entre los Estados, debiendo interpretarse según esta.
  - b. **Significado Corriente de los Términos del Tratado:** Esto se refiere al sentido técnico tributario que corresponda, no al que le den las personas comunes y corrientes.
  - c. **Contexto.**
  - d. **Objeto y Fin:** Esto según la misma terminología del tratado.

- 2) **Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:**
  - a. **Todo acuerdo que se refiere al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado.**
  - b. **Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.**
- 3) **Juntamente, con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:**
  - a. **Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones.**
  - b. **Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado.**
  - c. **Toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.**
- 4) **Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes.**

**2.2. Medios de Interpretación Complementarios (Art. 32 C. Viena):** Para (i) confirmar el sentido resultante de la aplicación del **Art. 31 C. Viena** o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con dicho artículo (ii) deje ambiguo u oscuro el sentido; o (iii) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo e irrazonable, se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a:

- 1) **Los Trabajos Preparatorios del Tratado (Comentarios de la OCDE):** En general la doctrina coloca aquí los comentarios de la OCDE, ya que lo vinculante es lo que está ratificado por los dos Estados, como el protocolo, el tratado y el intercambio de cartas. Pero como los comentarios no están acordados por los países están aquí. Hay otros autores que señalan que son parte del contexto para darle una mayor importancia.
- 2) **Las Circunstancias de su Celebración:** Se refiere a como concluye el proceso de negociación. En Chile nunca se han visto actas de las comisiones negociadoras, pero en otros países si se pueden invocar por existir dicha documentación.

**2.3. Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas (Art. 33 C. Viena):**

- 1) **Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos.**
- 2) **Una versión del tratado en idioma distinto de aquél en que haya sido autenticado el texto será considerado como texto auténtico únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.**
- 3) **Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto auténtico igual sentido.**
- 4) **Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conforme a lo previsto en el número 1, cuando la comparación de los textos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda resolverse con la aplicación de los artículos 31 y 32, se adoptará el sentido que mejor**

**concilie esos textos, habida cuenta del objeto y del fin del tratado:** En virtud de esta disposición uno podría señalar que el modelo en inglés prima por sobre otro idioma, porque los comentarios son en inglés, y estos se aplicarían por el **Art. 3 C. Viena**.

**2.4. Regla Supletoria en la Práctica:** En caso de que no sea posible resolver el conflicto de ningún modo, en la práctica no se da aplicación a la cláusula problemática. *Ejemplo: Entre Italia y Alemania se dio un conflicto entre el concepto de acciones y derechos sociales porque un CDTI hablaba solo de acciones y otro hacía referencia a ambos, por lo cual al final se decidió que esa cláusula no se aplicaba, debiendo usarse la cláusula residual para resolver la problemática.*

**3. Discusión del Oficio N° 2.890 del SII:** El caso consiste en si Chile puede retener las rentas respecto de servicios técnicos. El tema es que los servicios son prestados desde Perú, sin desplazamiento de personal, pero excepcionalmente había veces en que esto si ocurría, incluso más allá de 183 días.

El SII chileno determina que como los CDTI no son fuente de derecho tributario en sí mismos, sino que lo que hacen es distribuir la potestad tributaria, no debiendo hacer la tributación más gravosa, en este caso debía acudir a la normativa interna porque se trataba de un establecimiento permanente, lo cual implicaba que Chile podía gravar sin limitación alguna la renta. En este caso según el **Art. 59 N°2 LIR** por un impuesto adicional de retención del 20%.

**4. Comentarios de la OCDE:** Si bien son fuente de interpretación de los CDTI, se discute cuál es su valor. En cuanto a su naturaleza, no forman parte del CDTI, sino que nacen de un conjunto de expertos, por lo cual los Estados pueden realizar observaciones (interpretar de modo distinto) y reservas (negar la aplicación de un texto propuesto) a dichos comentarios.

Respecto a ellos, el SII en el Oficio N° 2.890 de 2005 señaló que no son jurídicamente vinculantes, ya que al provenir del Comité de Asuntos Fiscales el país podría apartarse de estos comentarios. Esto en la práctica no ocurre porque el Derecho Tributario Internacional funciona en la medida en que se tenga una interpretación común, buscando evitar la doble tributación internacional y la doble no tributación internacional.

Hay ciertos autores que ubican estos comentarios en lo que es el contexto. En este sentido, entrarían en la primera regla interpretativa. Pero en general va en la línea de la Convención de Viena sobre trabajos complementarios o preparatorios.

Ahora bien, no se ha planteado la discusión si los comentarios que se deben tomar en cuenta son los que ya se encontraban vigentes cuando se dio la situación o cuando esta deba ser interpretada. En general las jurisdicciones son reacias a considerar comentarios posteriores.

**5. Conflictos de Calificación:** Se da cuando se discuten las reglas distributivas para efectos de ver cuál es el país que tiene la jurisdicción limpia de una renta. Lo que se discute es la calificación jurídica del vínculo.

**5.1. Conflicto en la Interpretación y apreciación de los Hechos:** El CDTI se refiere al derecho interno para ver el sentido y alcance de alguna expresión.

**5.2. Art. 3 CDTI:** Hay una discusión sobre una interpretación estática o dinámica. En general la doctrina es más proclive a la interpretación dinámica, por lo que se evita esta especie de supervigencia de la normativa, en el sentido de interpretar los CDTI según normas antiguas que ya han perdido su vigencia, por lo que se cree que la nueva legislación se considera o se toma en cuenta para esto, con limite en los hechos que gatilló la aplicación del CDTI.

**5.3. Posición de la OCDE:** El país de residencia no puede excusar el otorgamiento de un crédito en un conflicto de calificación. Esto se funda en una frase del **Art. 23 CDTI** que señala que: “*de acuerdo con las disposiciones del presente convenio*”, donde se ve que, si hay un conflicto en la aplicación de este CDTI en sí, y se desconociera la regla, el país de residencia auténtica podría reclamar esta especie de convenio alternativo, pudiendo darse situaciones de doble tributación y de doble no tributación. Se busca que el país de residencia siga la calificación del país de la fuente.

## **IX. REGULACIÓN DE LAS RENTAS ACTIVAS.**

**1. Servicios Personales Independientes (Art. 14 CDTI):** “*Las rentas obtenidas por una persona natural que es residente de un Estado contratante, con respecto a servicios profesionales u otras actividades de carácter independiente llevadas a cabo en el otro Estado contratante pueden someterse en este último Estado*”.

- 1) **Servicio Profesional:** Comprende especialmente las actividades independientes de carácter científico, literario, artístico, educativo o pedagógico, así como las actividades independientes de médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogos, auditores y contadores.

En México se incluye también las personas jurídicas.

- 2) **Otras Actividades Independientes:** Ha generado una serie de problemas interpretativos, ya que colisiona con el **Art. 7 CDTI** que se refiere a beneficios empresariales. De ahí se ha concluido que el **Art. 14 CDTI** opera solo respecto de personas naturales y el **Art. 7 CDTI** opera respecto de sociedades. Además, el **Art. 7, párrafo 7 CDTI** señala que este no se aplicará si hay una norma especial, por lo que sería subsidiario.

### **1.1. Problemas de Aplicación:**

- 1) **Regalía con CDTI de Brasil y Colombia:** Un problema que genera la aplicación de este artículo es que, en Brasil y Colombia el concepto de regalía del **Art. 12 CDTI** incluye a los servicios técnicos y de consultoría, pudiendo tributar en fuente con un impuesto limitado al 10%. Una interpretación válida que podría sostenerse es que, al agregar al concepto de regalía estos servicios se está haciendo una contra excepción a los beneficios empresariales del **Art. 7 CDTI** sobre empresas, lo que permitiría aplicar el **Art. 14 CDTI** respecto de servicios personales realizados por personas naturales y el **Art. 12 CDTI** respecto de los mismos servicios realizados por personas jurídicas. Es decir, el **Art. 14 CDTI** mantiene su vigencia.
- 2) **Relación con el Art. 15 CDTI:** Este artículo habla de los servicios personales dependientes, existiendo un área gris entre los contratos de trabajo y los servicios personales independientes, sobre todo respecto de la calificación de un servicio prestado con subordinación y dependencia.
- 3) **Remisión al derecho interno según el Art. 3 §2:** Esto genera problemas de calificación, ya que para un país puede haber un servicio personal independiente y para otro puede haber un verdadero vínculo de subordinación y dependencia. Si se genera este conflicto el país de residencia no puede negar un método de exención o crédito por una calificación del país de fuente. En ese sentido, regiría la interpretación del país fuente para el caso concreto. Esto sin perjuicio de la facultad de denunciar el CDTI o negociar mutuamente este problema.

**1.2. Tributación:** La regla general es la tributación en residencia, salvo que se cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- 1) **Cuando la persona tenga en el Estado de la fuente una base fija de la que disponga regularmente para el desempeño de sus actividades:** En tal caso, solo puede someterse a imposición en el Estado de la fuente la parte de las rentas que sean atribuidas a dicha base fija. *Ejemplo:* Persona que tiene una oficina en el Estado donde presta el servicio. Se entiende por base fija “un lugar físico que tiene una cierta permanencia”. No se exige ningún plazo en particular.
- 2) **Cuando dicha persona permanezca en el Estado de la fuente por un periodo o periodos que, en total, sumen o exceden 183 días, dentro de un periodo cualquiera de 12 meses:** En tal caso, solo puede someterse a imposición en el Estado de la fuente la parte de la renta obtenida de las actividades desempeñadas por él en el Estado de la fuente.

Este criterio atiende a la presencia física, es decir, se cuenta desde el ingreso y se cuentan días completos y parcializados, los cuales se consideran como 1 día completo. También cuentan los días de vacaciones, feriados, días inhábiles, etc. Las únicas excepciones que plantea la OCDE son dos:

- a. **Cuando el contribuyente está de tránsito en el país:** *Ejemplo:* Juan va a Europa y debe pasar por Argentina.
- b. **Cuando hay una enfermedad que impide al contribuyente salir del país:** No cuenta ningún otro imprevisto como una huelga, solo enfermedades.

Puede darse un problema de aplicación de las disposiciones del CDTI, ya que ciertos países pueden tomar en consideración otros elementos para no sumar días. Ante ello la OCDE señala que hay que seguir el procedimiento de negociación mutua.

**1.3. Aplicación Actual:** Hoy en día este artículo fue eliminado del modelo por sus similitudes con el **Art. 7 CDTI** sobre beneficios empresariales y por la situación del establecimiento permanente, ya que no quedaba claro si base fija de negocios era lo mismo que establecimiento permanente. Esto llevó a que el **Art. 14 CDTI** migrara al **Art. 7 CDTI**.

A pesar de lo anterior, los CDTI firmados por Chile siguen incorporando este artículo por expresa intención de nuestro país para mantener una cierta consistencia. Ahora bien, su aplicación no ha sido uniforme, ya que hay casos en los que se autoriza a imponer impuestos en el país de la fuente. Sin embargo, en virtud de la “Cláusula de la Nación más favorecida”, el CDTI Chile-Canadá, que permitía la tributación en fuente, se vio modificado por los CDTI con Noruega y Polonia que siguen criterios generales.

## **2. Servicios Personales Dependientes (Art. 15 CDTI):**

**2.1. Párrafo 1:** “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 16, 18 y 19, los sueldos, salarios y otras remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado contratante en razón de un trabajo dependiente sólo pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que el trabajo dependiente se desarrolle en el otro Estado contratante. Si el trabajo dependiente se desarrolla en este último Estado, las remuneraciones derivadas del mismo pueden someterse a imposición en él”.

- 1) **Aplica en la medida que no sean aplicables el Art. 16 de los directores, el Art. 18 que se refiere a las pensiones y el Art. 19 que se refiere a los funcionarios públicos.**
- 2) **La regla general es que se tributa en el Estado donde se ejerce el empleo.**
- 3) **La norma remite al derecho interno para definir los conceptos de sueldo, salario y otras remuneraciones:** Esto puede generar problemas de interpretación.

- 4) **Solo aplica respecto de servicios dependientes:** Esto podría generar problemas de calificación en relación al concepto de vínculo de subordinación y dependencia.

**2.2. Párrafo 2:** *“2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las remuneraciones obtenidas por un residente de un Estado contratante en razón de un trabajo dependiente realizado en el otro Estado contratante sólo pueden someterse a imposición en el Estado mencionado en primer lugar si:*

- a) el perceptor permanece en el otro Estado durante un período o períodos cuya duración no exceda, en conjunto, de 183 días en cualquier período de doce meses que comience o termine en el año fiscal considerado, y*
- b) las remuneraciones son pagadas por, o en nombre de, un empleador que no sea residente del otro Estado, y*
- c) las remuneraciones no son soportadas por un establecimiento permanente que el empleador tenga en el otro Estado”.*

Estas condiciones son copulativas e implican que se tribute solo en el Estado de residencia.

### 2.3. Algunas Precisiones:

- 1) **Diferencia entre “Contract of Services” y “Contract for Services”:** Cuanto tenemos un contrato de prestación de servicios y este no es remoto, sino que implica el traslado de personas tendremos un contrato regido por un beneficio empresarial del **Art. 7 CDTI** y, además, tendremos un contrato de trabajo entre el empleador y el empleado regido por el **Art. 15 CDTI**. Además, si el trabajador se queda por más de 183 días podría generarse un establecimiento permanente, afectando ambos artículos.
- 2) **Este artículo se puede utilizar para evitar la conformación de un Establecimiento Permanente.**
- 3) **Crédito por impuestos pagados en el exterior “de acuerdo a las disposiciones del CDTI”:** Esto quiere decir que el país de la Residencia debe otorgar un crédito por el impuesto soportado en fuente.

**2.4. Criterios para apreciar el Vínculo de Subordinación y Dependencia (Comentario 8.14 del Art. 15 CDTI):** Cuando la comparación de la naturaleza de los servicios prestados por la persona física con la actividad ejercida por su empleador formal y por la empresa a la que se presta los servicios revela una relación de trabajo dependiente que difiere de la relación contractual formal, los criterios que siguen pueden ayudar a determinar si este es realmente el caso:

- 1) **Naturaleza de los servicios y vínculo con la actividad de la empresa (riesgo y responsabilidad):** En la medida que los riesgos y la responsabilidad queden radicados en la empresa estaremos frente a un vínculo de subordinación y dependencia.
- 2) **Quién está facultado para dar instrucciones al trabajador en relación con el modo en que debe realizarse el trabajo;**
- 3) **Quién controla el lugar en el que se lleva a cabo el trabajo y es responsable de él:** Hay contratos de construcción donde el mandante pone el lugar a disposición del contratista y este pone su trabajo y su personal a la obra. Si bien el dominio del bien es del que contrata, es el contratista quien controla ese lugar, los horarios y el trabajo allí.
- 4) **El empleador formal factura la remuneración percibida por la persona física directamente a la empresa que percibe los servicios:** Podría ocurrir que se pacte pagar directamente al trabajador

y que luego se reembolse a la empresa por dicho pago. Puede haber un **Art. 7 CDTI y 15 CDTI** a la vez, ya que una cosa es la remuneración que se pagan entre empresas y otra la que se pagan el empleador con su trabajador. Este criterio apunta a quien soporta el gasto porque puede haber acuerdos empresariales. Es importante ver si el acuerdo empresarial va más allá del desplazamiento de la persona o no.

- 5) **Quién pone a disposición del trabajador las herramientas y el material necesario;**
- 6) **Quién determina el número de personas para el desarrollo del trabajo y su cualificación;**
- 7) **Quién está facultado para elegir a la persona que ejecutará el trabajo y para poner fin a la relación contractual establecida con el trabajador a ese fin;**
- 8) **Quién está facultado para imponer medidas disciplinarias en relación con el trabajo efectuado por esa persona;**
- 9) **Quién determina los períodos de vacaciones y el horario de trabajo de esa persona.**

Hay que ir ponderando cuáles criterios se cumplen, cuales son esenciales, etc.

## 2.5. Algunas Actividades Particulares:

- 1) **Training Services (Comentarios 8.16 y 8.17 Art. 15 CDTI):** *Ejemplo:* Aco, una sociedad residente en el Estado A, celebra un contrato con Bco, sociedad residente del Estado B, para la prestación de servicios de formación. Aco está especializada en formar al personal para la utilización de diferentes aplicaciones informáticas –software- y Bco desea formar a su personal en la utilización de una aplicación recientemente adquirida. Se envía a X, un empleado de Aco, residente del Estado A a las oficinas de Bco en el Estado B para que imparta los cursos de formación en el marco de ese contrato. En ese caso, el Estado B no puede sostener que X tiene una relación de trabajo dependiente con Bco o que Aco no es el empleador de X a los efectos de la aplicación del convenio entre los Estados A y B. X es formalmente un empleado de Aco. Por tanto, siempre que X no esté presente en el Estado B durante más de 183 días durante un período de 12 meses y que Aco no tenga en el Estado B un establecimiento permanente que soporte la carga de la remuneración de X, la excepción prevista en el apartado 2 del artículo 15 sería aplicable a la remuneración de X.
- 2) **Servicios de Marketing Intragroup (Comentarios 8.18 y 8.19 Art. 15 CDTI):** *Ejemplo:* Cco es una sociedad residente del Estado C, matriz de un grupo de sociedades entre las que se encuentra Dco, una sociedad residente del Estado D. Cco ha desarrollado una nueva estrategia de comercialización mundial para los productos del grupo. Con la intención de garantizar que Dco entiende y aplica correctamente la estrategia, siendo esta última quien vende los productos del grupo, Cco envía a X, uno de sus empleados que ha trabajado en el desarrollo de la estrategia, para trabajar en la sede de Dco durante 4 meses, a fin de instruir a Dco en relación con su comercialización y garantizar que el departamento de comunicaciones de Dco entiende y cumple la estrategia de comercialización mundial. En ese caso, la actividad de Cco incluye la gestión de las actividades de comercialización mundial del grupo y los propios servicios de X están integrados en esa actividad. Si bien podría argüirse que fácilmente Dco podría haber contratado a un empleado para el desarrollo de la función de asesoramiento de la sociedad en relación con la comercialización, es obvio que frecuentemente son los consultores quienes desarrollan esa actividad, especialmente cuando es necesario contar con unos conocimientos especializados y durante un plazo de tiempo breve. Igualmente, la función de control del cumplimiento de la

*estrategia de comercialización mundial se enmarca en la actividad de Cco, más que en la de Dco. La excepción del apartado 2 del artículo 15 debe aplicarse, por tanto, siempre que se satisfagan las restantes condiciones para su aplicación.*

- 3) **Traspaso de Trabajadores entre Filiales de distintos países (Comentarios 8.20 y 8.21 Art. 15 CDTI):** *Ejemplo:* Una multinacional posee y explota hoteles en todo el mundo a través de una serie de filiales. Eco, una de ellas, es residente del Estado E en el que posee y explota un hotel. X es un empleado de Eco que trabaja en ese hotel. Fco, otra filial del grupo, posee y explota un hotel en el Estado F en el que hay carencia de empleados con competencia en lenguas extranjeras. Con tal motivo, se envía a X a trabajar durante 5 meses a la recepción del hotel de Fco. Fco paga los gastos de viaje a X, que formalmente continúa adscrito a Eco, de quien sigue además percibiendo su remuneración; Fco paga a Eco unos honorarios de gestión por razón de la remuneración de X, las contribuciones a sus seguros sociales y otros beneficios derivados de su condición de empleado durante el período en cuestión. En ese caso, el trabajo desempeñado en la recepción del hotel del Estado F puede considerarse parte integrante de la actividad económica de Fco consistente en la explotación de ese hotel, en lugar de parte de la actividad de Eco. Según el criterio descrito anteriormente si, en virtud de la normativa interna de F, los servicios de X se consideran prestados a Fco por razón de una relación de trabajo dependiente, el Estado F podría lógicamente considerar que Fco es el empleador de X, dejando sin aplicación la excepción del apartado 2 del artículo 15.
- 4) **Empresa de Provisión de Persona Técnico (Comentario 8.22 y 8.23 Art. 15 CDTI):** *Ejemplo:* Gco es una sociedad residente del Estado G. Su negocio consiste en satisfacer la necesidad de las empresas de contar temporalmente con personal altamente especializado. Hco es una sociedad residente del Estado H que presta servicios de ingeniería en obras. A fin de dar cumplimiento a uno de sus contratos en el Estado H, Hco precisa un ingeniero para un plazo de 5 meses y contacta con Gco a tal fin. Gco contrata a X, un ingeniero residente del Estado X con quien firma un contrato de trabajo de 5 meses. En un contrato distinto celebrado entre Gco y Hco, Gco acuerda prestar los servicios de X a Hco durante ese período. En virtud de estos contratos, Gco se hará cargo de la remuneración de X, sus cotizaciones a los seguros sociales, los gastos de viaje y otras percepciones y gastos relacionados con su empleo. En ese caso, X presta servicios de ingeniería, mientras que la actividad de Gco es la de dar satisfacción a las necesidades a corto plazo de otras empresas. Por su propia naturaleza, los servicios prestados por X no constituyen una parte de la actividad económica de su empleador formal. Estos servicios, sin embargo, sí se integran en la actividad económica de Hco, una empresa de ingeniería. En vista de esto el Estado H podría, por tanto, considerar que, según el criterio visto anteriormente, la excepción del apartado 2 del artículo 15 sería inaplicable a la remuneración por los servicios prestados por el ingeniero en ese Estado.

- 5) **Profesores Visitantes:** Porque muchas veces las universidades de destino fijan vacaciones.

### **3. Beneficios Empresariales (Art. 7 CDTI):**

**3.1. Párrafo 1:** “Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios imputables al establecimiento permanente de conformidad con las disposiciones del apartado 2 pueden someterse a imposición en ese otro Estado”.

Es decir, los beneficios de una empresa solo tributan en el Estado de la residencia, salvo que en el Estado de la fuente haya un establecimiento permanente. Si hay un establecimiento permanente el país de la fuente puede gravarlo.

Ahora bien, los beneficios empresariales que tributan en el país fuente son los beneficios empresariales atribuidos a la actividad que realiza el establecimiento permanente. Es decir, no todo beneficio empresarial es gravado como tal, solo los atribuibles a los establecimientos permanentes.

Respecto a los CFC, la OCDE ha dicho que la extensión del concepto de establecimiento permanente puede generar un problema con el concepto de CFC porque atribuye utilidades que no quedan gravadas en el país de residencia. La OCDE ha dicho que en este caso se aplica el **Art. 9 CDTI**.

**3.2. Párrafo 2:** *“A los efectos de este artículo, y del artículo [23 A] [23 B], los beneficios imputables al establecimiento permanente en cada Estado contratante a los que se refiere el apartado 1 son aquellos que el mismo hubiera podido obtener, particularmente en sus operaciones con otras partes de la empresa, si fuera una empresa distinta e independiente que realizase actividades idénticas o similares, en las mismas o análogas condiciones, teniendo en cuenta las funciones desarrolladas, los activos utilizados y los riesgos asumidos por la empresa a través del establecimiento permanente y de las restantes partes de la empresa”.*

Hay una ficción en el sentido de que el CDTI dice que el establecimiento permanente es una entidad distinta e independiente del controlador.

Hay dos etapas:

- 1) **Determinar los Beneficios y Gastos que se deben considerar:** Este es un análisis funcional y factual:
  - a. **Atribución de derechos y obligaciones al Establecimiento Permanente:** La empresa realiza la actividad y por eso tiene derechos y obligaciones. Si le agregamos la fuerza de atracción hay que determinar cuál es la actividad para asignarles esos derechos y obligaciones.
  - b. **Identificación de las funciones humanas sustantivas:** Ver cuál es la actividad que realiza el establecimiento permanente. Es necesario saber la actividad que realiza el Establecimiento Permanente a fin de determinar su balance.
  - c. **Determinación de la propiedad económica sobre los activos:** Una vez que tenemos el balance armado, el país de la fuente tiene potestad para gravar ese balance. De ahí puede haber ciertas diferencias en la determinación de las utilidades de un país a otro.
  - d. **Determinación de los riesgos que asume el Establecimiento Permanente:** Para efectos de los gastos.
  - e. **Atribución de capital sobre la base de los activos y riesgos atribuidos al Establecimiento Permanente.**
  - f. **Apreciación de relaciones *intra holding*:** Puede ocurrir que un establecimiento permanente compra o recibe un producto que vende en el mercado local. Dicho producto es comprado a la matriz u a otra empresa dentro del mismo holding. Aquí juega el *transfer pricing*.
- 2) **Análisis de los Precios de Mercado:** Como se presume que un Establecimiento Permanente tiene relaciones con su controlador como con otras empresas del mismo grupo, la norma del *transfer pricing* tiene mucha aplicación práctica.
  - a. **Determinación de precios en las transacciones entre partes relacionadas.**

- b. Búsqueda del comparable para determinar cuál es el precio justo:** La doctrina ha determinado que encontrar un comparable es sumamente difícil.
- c. Aplicación de algunos de los métodos de *Transfer Pricing* a fin de determinar precios justos.**

**3.2.1. Consecuencias de la Ficción de la Empresa Distinta e Independiente:** La idea del Establecimiento Permanente es analogarla a una filial. Es necesario atribuir los beneficios al establecimiento permanente para que tribute. Los ejercicios hay que determinarlos como si tuviera el carácter de filial. Es por esta razón que se evita el establecimiento permanente, porque es difícil realizar la separación entre matriz y establecimiento permanente.

- 1) Esta ficción solo opera respecto del Art. 7 CDTI en relación al Art. 23 CDTI:** Por lo que no afecta a otros artículos del mismo. Esto tiene relación con el principio de atracción, y porque al hacer el balance, a esta empresa distinta o independiente también debo atribuirle ciertas cosas que están dentro del ejercicio ficto.
- 2) Determinación de la base imponible queda entregada al derecho interno:** Una vez hecho el balance del establecimiento permanente se entrega al país de la fuente para que determine los impuestos a pagar. En este contexto, se deja a las normas internas la generación de la base imponible.
- 3) Situación de las restricciones del derecho interno a la deducción de gastos:** Puede haber ciertos requisitos adicionales, es decir, quizás estoy atribuyendo ciertos gastos fictos donde no se cumplen los requisitos legales. *Ejemplo: Atribuyo intereses, pero como se debe tributar cuando se pagan y estos nunca se pagaron se generan problemas.*
- 4) Incidencia de la cláusula que prohíbe discriminaciones:** Un Establecimiento Permanente en la deducción de los gastos está sujeta a toda empresa propiamente tal en el país donde se está tributando, aun cuando sea ficto. El **Art. 22 CDTI** dice que el establecimiento permanente de ser valorado como empresa residente en el país de fuente.

**3.3. Párrafo 3:** *“Cuando de conformidad con el apartado 2 un Estado contratante ajuste los beneficios imputables al establecimiento permanente de una empresa de uno de los Estados contratantes y, en consecuencia, grave los beneficios de la empresa que ya han sido gravados por el otro Estado, ese otro Estado, en la medida en que sea necesario para eliminar la doble imposición sobre dichos beneficios, practicará el ajuste correspondiente en la cuantía del impuesto aplicado sobre los mismos. En caso necesario, las autoridades competentes de los Estados contratantes se consultarán para la determinación de dicho ajuste”.*

Este artículo señala que, antes de aplicar el crédito del **Art. 23 CDTI**, se deben hacer ajustes en ambas jurisdicciones para evitar la generación de una doble tributación. En definitiva, es una norma destinada a prevenir la doble tributación al determinar los beneficios del establecimiento permanente.

En ese contexto, tenemos dos ajustes:

- 1) Uno inicial por el país que parte o inicia el mecanismo:** Como el que realiza un país al momento de fiscalizar.
- 2) Uno correlativo que busca evitar la doble tributación.**

Los ajustes pueden darse en cualquiera de los Estados. Incluso, puede hacerse un reajuste inicial en ambos Estados.

**3.3.1. Límites dentro del cual se hacen los reajustes:** No es determinado en el CDTI, pero en Chile se hace dentro del plazo de prescripción de la acción de fiscalización.

Esta norma solo aplica respecto de la distribución de beneficios y gastos, no determina la base imponible que queda entregada al país de la fuente y no afecta el crédito o exención.

**3.4. Párrafo 4:** *“Cuando los beneficios comprendan elementos de renta regulados separadamente en otros artículos de este Convenio, las disposiciones de dichos artículos no quedarán afectadas por las del presente artículo”.*

En virtud de este párrafo, Chile interpreta que todo beneficio que recibe una empresa o persona independiente termina en el **Art. 7 CDTI**.

### **3.5. El Art. 7 CDTI en Chile:**

- 1) **Párrafo 1:** No introduce un cambio significativo.
- 2) **Párrafo 2:** *“Sujeto a lo previsto en el párrafo 3, cuando una empresa de un Estado Contratante realice su actividad en el otro Estado Contratante por medio de un establecimiento permanente situado en él, en cada Estado Contratante se atribuirán a dicho establecimiento los beneficios que éste hubiera podido obtener de ser una empresa distinta y separada que realizase las mismas o similares actividades, en las mismas o similares condiciones y tratase con total independencia con la empresa de la que es establecimiento permanente y con todas las demás personas”.* A diferencia del párrafo actual, este no establece criterios para realizar la ficción.
- 3) **Párrafo 3:** *“Para la determinación de los beneficios del establecimiento permanente se permitirá la deducción de los gastos necesarios realizados para los fines del establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y generales de administración para los mismos fines, tanto si se efectúan en el Estado en que se encuentre el establecimiento permanente como en otra parte”.* Este párrafo se cambió porque era muy difícil distribuir los gastos entre el controlador y las empresas del grupo, incluido el establecimiento permanente.
- 4) **Párrafo 4:** *“Mientras sea usual en un Estado Contratante determinar los beneficios imputables a un establecimiento permanente sobre la base de un reparto de los beneficios totales de la empresa entre sus diversas partes, lo establecido en el párrafo 2 no impedirá que ese Estado Contratante determine de esta manera los beneficios imponibles; sin embargo, el método de reparto adoptado habrá de ser tal que el resultado obtenido sea conforme a los principios contenidos en este Artículo”.* Este párrafo hacía mención al sistema de reparto, donde se asigna la proporción de ingresos y gastos entre los distintos miembros del grupo. Este decía razón con la importancia de las entidades, repartiéndose una proporción entre unas y otras. Este método se eliminó.
- 5) **Párrafo 5:** *“No se atribuirá ningún beneficio a un establecimiento permanente por el mero hecho de que éste compre bienes o mercancías para la empresa”.* Hoy este párrafo se encuentra en el **Art. 5 CDTI** que habla sobre cómo constituir un Establecimiento Permanente.
- 6) **Párrafo 6:** *“A efectos de los párrafos anteriores, los beneficios imputables al establecimiento permanente se calcularán cada año por el mismo método, a no ser que existan motivos válidos y suficientes para proceder de otra forma”.* Se eliminó porque las guías de la OCDE de cómo

determinar los beneficios atribuibles a los Establecimientos Permanentes ya tienen un sistema rígido, por lo que era redundante.

- 7) **Párrafo 7:** *“Cuando los beneficios comprendan rentas reguladas separadamente en otros Artículos de este Convenio, las disposiciones de aquéllos no quedarán afectadas por las del presente Artículo”.*
- 8) **Párrafo 8:** *“La renta o ganancia atribuible a un establecimiento permanente durante su existencia es imponible en el Estado Contratante donde tal establecimiento permanente este situado, aunque los pagos sean diferidos hasta que ese establecimiento permanente haya dejado de existir”.* Solo se encuentra en el CDTI con Francia y prohíbe, por la vía de la planificación, que se dejen gastos adeudados hasta que el Establecimiento Permanente desaparezca.

**4. El Establecimiento Permanente (Art. 5 CDTI):** El Art. 5, párrafo 1 CDTI lo define como *“lugar fijo de negocios mediante el cual una empresa realiza toda o parte de su actividad”.*

- 1) **Lugar de Negocios:** Da lo mismo el título jurídico que emplee la empresa, si es arrendatario, usuario o propietario. Basta con que la autoridad acredite que hay presencia en un lugar para que se dé este requisito. Incluso, los comentarios de la OCDE han dicho que la ocupación del lugar puede ser ilegal para cumplir con el requisito, es decir, no requiere de título jurídico.
- a. **Debe estar a disposición de la empresa:** La empresa debe servirse de este lugar para el desarrollo de su actividad. Ejemplo Práctico: *Empresa de asesoría quiere ampliarse y contacta a una empresa que tiene oficinas, por lo que contrata unas oficinas para que su auditor pueda realizar actividades y trabajos, y luego vuelve a su lugar de origen. En este caso el edificio de oficinas estuvo a disposición del desarrollo de la actividad comercial. En cambio, no habría tal disposición cuando tenemos un transportista que utiliza un muelle permanente para descargar y cargar bienes de un cliente, porque no está a disposición del sujeto particular, sino que sirve para una actividad accesorio.*
  - b. **El lugar no requiere exclusividad.**
- 2) **Lugar Fijo:** Apunta a un elemento territorial físico. Esto implica cierta permanencia, la cual según la OCDE debe ser igual o superior a 6 meses. Sin embargo, esto queda entregado a la apreciación de la autoridad administrativa correspondiente.
- a. **Debe haber unidad geográfica y comercial respecto del lugar:** Así, habría un lugar fijo si la empresa cambia de oficina en una misma región, ya que se entiende que hay unidad geográfica y comercial en dicha oficina aun cuando cambie constantemente de lugar físico. Ejemplo: *Trabajador que se desplaza en sucursales de una misma empresa vs trabajador que se desplaza en sucursales de distintas filiales. En el primer caso hay unidad comercial y geográfica, en el segundo no hay unidad comercial porque cada filial es una persona jurídica distinta.*
  - b. **Interrupción del plazo:** La OCDE ha dicho que, si hay una regularidad, no obstante las interrupciones, se cumple con el requisito de la permanencia.
  - c. **Celebración de distintos actos jurídicos separados pero que en conjunto tienen una unidad comercial:** Si miramos estos contratos por separado podríamos decir que no hay permanencia, pero si los miramos en conjunto podemos decir que hay permanencia. Se puede sostener que es un solo servicio dividido en varias secciones.

- d. **Circunstancias que, no obstante el inicio de una actividad en otro Estado, abruptamente terminan las relaciones económicas:** Estas circunstancias permiten que, si bien se buscaba una permanencia, se rompa por circunstancias anómalas.
- 3) **Mediante el cual:** Debe haber una disposición para realizar la actividad. *Ejemplo: La construcción de una carretera, ya que el lugar donde se emplaza es un lugar fijo mediante el cual el sujeto realiza la actividad.*
- 4) **Realización de todo o parte de actividades empresariales:**
- a. **Inicio:** Se entiende que hay establecimiento permanente desde el inicio de la realización de la actividad empresarial, aun cuando en un inicio no hay una idea de permanencia. Es decir, opera retroactivamente.
  - b. **Término:** El establecimiento permanente termina una vez realizada la actividad, cuando se venden los activos, etc.
  - c. **Interrupciones:** Puede haber interrupciones como la terminación de un contrato, pero manteniendo los activos y la maquinaria, esperando un nuevo contrato. En estos casos hay que analizar su regularidad. Por regla general la interrupción no se descuenta, si se sigue la actividad se entiende que se mantuvo durante el intertanto.
  - d. **Arrendamiento de los Activos:** Si se arriendan los activos asociados al establecimiento permanente, este se termina porque el arrendador deja de tener una presencia. Se pasa de una renta activa a una pasiva.
- 5) **¿Actividad Productiva?:** La OCDE ha señalado que no es necesario que el establecimiento permanente realice una actividad productiva.

La regla general es que solo se tribute en el país de residencia, pero si hay un establecimiento permanente, por dichas rentas se tributará en el país fuente.

**4.1. Párrafo 2:** “La expresión “establecimiento permanente” comprende, en especial:

- a) las sedes de dirección;
- b) las sucursales;
- c) las oficinas;
- d) las fábricas;
- e) los talleres; y
- f) las minas, los pozos de petróleo o de gas, las canteras o cualquier otro lugar de extracción de recursos naturales”: Esto no incluye las actividades de prospección, sino que debe ser de explotación propiamente tal.

**4.2. Párrafo 3:** “Una obra o un proyecto de construcción o instalación sólo constituye establecimiento permanente si su duración excede de doce meses”. Esto no ha sido seguido totalmente por los distintos países:

- 1) **Situación de Oficinas o Talleres:** Puede ocurrir que la oficina tenga una mayor permanencia que el proyecto, por eso es necesario distinguir el propio proyecto con la oficina.

- 2) **Proyecto de Construcción e Instalación:** No solo suponen la construcción en sí misma, sino que también incluye la reparación. Ambos incluyen construcciones o instalaciones amplias, no solo edificios, sino que puentes, túneles, etc. Si hay vínculos con varios mandantes se entiende que no se cumple con el requisito, mientras que si hay uno solo que manda remodelar varias oficinas si se cumpliría con el requisito.
- 3) **Actividades de Planificación y Supervisión:** Los plazos del establecimiento permanente comienzan a contar desde que se inician los trabajos. Por el solo puntapié inicial se da inicio al cómputo de los plazos.
- 4) **Computo del plazo es por cada proyecto, sin perjuicio de que la unidad comercial y geográfica pueda determinar otra cosa.**
- 5) **Fraccionamiento de contratos (temporalidad y sujetos contratantes):** Si es necesario suspender por un tiempo las labores no se obsta el plazo de los 12 meses, entendiendo que nunca se interrumpió el servicio. Esto salvo que en realidad la interrupción sea notoria o por un tiempo prolongado que impida identificar la unidad.
- 6) **Es importante el inicio, termino y las interrupciones.**
- 7) **Desarrollo de actividades a través de subcontratistas:** También son imputables al contratista principal. No se puede oponer la subcontratación como excusa.

**4.2.1. Párrafo 3 en Chile:** *“La expresión “establecimiento permanente” también incluye:*

- a) *una obra o proyecto de construcción, instalación o montaje y las actividades de supervisión relacionadas con ellos, pero sólo cuando dicha obra, proyecto de construcción o actividad tenga una duración superior a seis meses, y*
- b) *la prestación de servicios por parte de una empresa, incluidos los servicios de consultorías, por intermedio de empleados u otras personas naturales encomendados por la empresa para ese fin, pero sólo en el caso de que tales actividades prosigan en el país durante un período o períodos que en total excedan de 183 días, dentro de un período cualquiera de doce meses.*

*A los efectos del cálculo de los límites temporales a que se refiere este párrafo, las actividades realizadas por una empresa asociada a otra empresa en el sentido del Artículo 9, serán agregadas al período durante el cual son realizadas las actividades por la empresa de la que es asociada, si las actividades de ambas empresas son idénticas, sustancialmente similares o están conectadas entre sí”.*

Lo relevante del segundo caso es que basta con que haya personas, aun cuando no se realice un hecho en particular.

**4.3. Párrafo 4:** *“No obstante las disposiciones anteriores de este artículo, se considera que la expresión “establecimiento permanente” no incluye:*

- a) *la utilización de instalaciones con el único fin de almacenar, exponer o entregar bienes o mercancías pertenecientes a la empresa;*
- b) *el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de almacenarlas, exponerlas o entregarlas;*
- c) *el mantenimiento de un depósito de bienes o mercancías pertenecientes a la empresa con el único fin de que sean transformadas por otra empresa;*

- d) *el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de comprar bienes o mercancías o de recoger información para la empresa;*
- e) *el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar para la empresa cualquier otra actividad de carácter auxiliar o preparatorio;*
- f) *el mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el único fin de realizar cualquier combinación de las actividades mencionadas en los subapartados a) a e), a condición de que el conjunto de la actividad del lugar fijo de negocios que resulte de esa combinación conserve su carácter auxiliar o preparatorio”.*

Este párrafo lo que hace es excluir aquellas actividades accesorias o auxiliares, que no pueden ser calificadas como establecimiento permanente.

**4.4. Párrafo 5:** *“No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, cuando una persona distinta de un agente independiente (al que le será aplicable el apartado 6) actúe por cuenta de una empresa y tenga y ejerza habitualmente en un Estado contratante poderes que la faculten para concluir contratos en nombre de la empresa, se considerará que esa empresa tiene un establecimiento permanente en ese Estado respecto de las actividades que dicha persona realice para la empresa, a menos que las actividades de esa persona se limiten a las mencionadas en el apartado 4 y que, de haber sido realizadas por medio de un lugar fijo de negocios, no hubieran determinado la consideración de dicho lugar fijo de negocios como un establecimiento permanente de acuerdo con las disposiciones de ese apartado”.*

Lo que hace este artículo es aplicar todo lo señalado en los párrafos precedentes a los casos en que existe un agente que actúa con poderes suficientes a nombre de una empresa. Este, por regla general, se considerará a sí mismo como una constitución de un establecimiento permanente, salvo que realice las actividades accesorias del **Art. 5, párrafo 4 CDTI**.

- 1) Esta persona puede ser natural o jurídica, incluso puede ser un no residente del país donde realiza las actividades.**
- 2) No es necesario que actúe a nombre de la empresa, basta que la actuación sea vinculante.**
- 3) Los poderes deben referirse a la actividad propia de la empresa.**
- 4) No es necesaria la existencia de un vínculo de subordinación y dependencia.**
- 5) Los poderes deben ser ejercidos repetidamente.**

Estos criterios no son copulativos.

El concepto de este párrafo se acerca a lo que nuestra legislación entiende por Agencia. Ahora bien, la OCDE señala que no basta con el poder, se debe cumplir con lo señalado en el **Art. 5, párrafo 1 CDTI**, lo cual genera una fricción entre el CDTI y el derecho interno.

**4.5. Párrafo 6:** *“No se considera que una empresa tiene un establecimiento permanente en un Estado contratante por el mero hecho de que realice sus actividades en ese Estado por medio de un corredor, un comisionista general o cualquier otro agente independiente, siempre que dichas personas actúen dentro del marco ordinario de su actividad”.*

Este artículo reconoce que cada empresa dentro de una organización tiene su propia individualidad. La OCDE explicita el criterio sobre agentes independientes, reconociendo que las empresas que actúan a través de ellos no generan un vínculo de establecimiento permanente. Hay dos elementos:

- 1) **Debe tratarse de dos entidades jurídica y económicamente independientes:** Es importante revisar el alcance de las obligaciones y dónde quedan radicados los riesgos.
- 2) **Se debe actuar en el ejercicio normal de la actividad:** Debe ser un comisionista o agente de venta, no basta con que la realidad diga algo distinto.

**4.6. Párrafo 7:** *“El hecho de que una sociedad residente de un Estado contratante controle o sea controlada por una sociedad residente del otro Estado contratante o que realice actividades empresariales en ese otro Estado (ya sea por medio de establecimiento permanente o de otra manera), no convierte por sí solo a cualquiera de estas sociedades en establecimiento permanente de la otra”.*

Esto se relaciona con que las distintas sociedades dentro de una organización tienen su propia individualidad. Así es como la filial o la matriz pueden por si mismas devengar un establecimiento permanente, pero en la medida que cada una individualmente cumpla con los párrafos 1 y 5.

**4.8. Caso Amazon y Desafíos Pendientes:** Se cuestiona si existe o no un establecimiento permanente de Amazon en UK. Ante ello la autoridad tributaria británica señala que no hay presencia tributaria en Inglaterra porque es una empresa de Amazon en Luxemburgo la que realiza la venta, que es la actividad principal de Amazon. En UK solo se trasladan los bienes desde las bodegas. Incluso las rentas descienden a Luxemburgo.

Frente a estos casos Francia ha decidido emprender en el G20 una discusión para determinar el concepto de establecimiento permanente electrónico.

## **X. REGULACIÓN DE LAS RENTAS PASIVAS.**

Mientras en las rentas activas hay un beneficio de la estructura legal y estructural del país que genera una mayor predisposición a que estas se graven en fuente, en el caso de las rentas pasivas hay una mayor predisposición a liberarlas en el país fuente.

Por regla general, cuando hay un pago por parte de un deudor con domicilio en Chile a un acreedor con domicilio en el extranjero, aparece una norma de control de retención en el país fuente por parte de quien paga la renta.

### **1. Los Intereses (Art. 11 CDTI):**

**1.1. En la Ley de Impuesto a la Renta:** La regla general es que tributen según el impuesto adicional de un 35%. Excepcionalmente tributarán con una tasa del 4%, cuando provengan de:

- 1) **Instituciones bancarias o financieras extranjeras o internacionales.**
- 2) **Compañías de Seguros.**
- 3) **Fondos de Pensiones.**
- 4) **Bonos o Debentures.**
- 5) **Instrumentos de deuda de oferta publica del Art. 104 LIR.**

Su base imponible es el monto bruto, sin deducción alguna.

Ahora bien, esta excepción del 4% se pierde si la deuda excede en 3 veces el patrimonio efectivo de la sociedad deudora, debiendo tributar por el exceso con la tasa del 35% del impuesto adicional.

**1.2. Párrafo 1:** *“Los intereses procedentes de un Estado contratante y pagados a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado”.*

Esto quiere decir que, por regla general, es el Estado de la residencia del acreedor quien tiene derecho a imponer impuestos.

1) **Pagados:** La OCDE dice que esto es amplio, suponiendo un pago o cualquier forma en que el interés sea puesto a disposición del acreedor. En Chile el **Art. 74 LIR** señala que se entiende por tal:

a. **Pago y extinción de las obligaciones por alguna forma alternativa.**

b. **Abono en cuenta:** Se genera una cuenta contable específica a nombre del acreedor con los intereses a disposición de este.

c. **Puesta a disposición del interesado.**

d. **Contabilización del gasto:** A diferencia de las demás, esta no genera la obligación de retención y pago.

En los primeros tres casos se debe retener el impuesto y dentro de los 12 días del mes siguiente se deben declarar y pagar.

**1.3. Párrafo 2:** *“Sin embargo, dichos intereses pueden someterse también a imposición en el Estado contratante del que procedan y según la legislación de ese Estado, pero si el beneficiario efectivo de los intereses es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del 10 por 100 del importe bruto de los intereses. Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de ese límite”.*

Esto permite imponer en el Estado de la fuente impuestos, pero siempre que no superen del 10% del importe bruto de los intereses.

Ahora bien, en Chile se han utilizado distintos CDTI para regular el %, existiendo algunos casos en que solo se puede tributar con un 5% y los demás se podría con un 15% como cláusula general. En este sentido, hay que tener mucho cuidado con la cláusula de la nación más favorecida.

Recordar que, si se puede aplicar el 4% del derecho interno, este prima por sobre el CDTI porque solo el derecho interno puede crear hechos gravados.

**1.3.1. Beneficiario Efectivo:** Este término cumple la función de control anti elusivo de los CDTI. No es una interpretación técnica, sino que se traen indirectamente los conceptos de la Convención de Viena, Esto tiene que estar presenta para efectos de entender el concepto.

1) **Mandatarios o Agentes:** Se busca el control entre el beneficiario efectivo del interés y el deudor, buscando evitar que se vea beneficiado por un CDTI un residente de un Estado que no es parte del mismo. Es evidente que en este caso el beneficiario efectivo será el mandante, aun cuando dicho mandato sea sin representación.

2) **Intermediarios y Personas con Poderes Limitados:** Esto es en el sentido de que puede no existir un mandato, y la autoridad no puede probar que hay una relación mandante-mandatario. Pero si puede probar que en los hechos la persona que recibe el interés no es el beneficiario efectivo, ya que no tiene los recursos suficientes para disponer de forma arbitraria de estos intereses, estando obligado a remesarlos a una tercera persona.

- 3) **Sociedades Instrumentales (Conduit Companies):** Estas tienen un desarrollo bastante extenso por la OCDE y se trata de la interposición de una sociedad entre el beneficiario efectivo y el deudor del interés.
- 4) **Poderes Restringidos:** Tiende a caracterizar una sociedad instrumental.
- 5) **Fiduciario o Administrador que actúa por cuenta de terceros:** Tiende a caracterizar una sociedad instrumental.
- 6) **Acuerdos Instrumentales:** Facultad de disponer de la renta y obligación de traspasarla a un tercero.

Se debe ver si se tiene una base fija en el lugar donde dice ser residente, con un domicilio informado a la autoridad. En segundo lugar, en este domicilio o base fija debiera tener activos. En tercer lugar, estos activos deben ser adecuados para poder cumplir con los fines que esta entidad informa y declara que realiza. Además, esta entidad tiene que asumir riesgos inherentes a la actividad. Por último, debe tener facultades o debe haber una funcionalidad suficiente para el desarrollo de la actividad.

Desde un punto de vista económico, en primer lugar, se debe ver si hay una obligación legal o en los hechos de pagar o traspasar estos beneficios a un tercero, ya que lo que hace esto es impedir disponer de la renta de los intereses. Otro elemento es la existencia de garantías, porque si un tercero puede otorgar garantías de forma tal que hace suponer que esta sociedad instrumental esta apalancada, para efectos de que un tercero garantice la actividad.

**1.4. Párrafo 3:** *“El término “intereses”, en el sentido de este artículo, significa las rentas de créditos de cualquier naturaleza, con o sin garantía hipotecaria o cláusula de participación en los beneficios del deudor, y en particular las rentas de valores públicos y las rentas de bonos y obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a esos títulos. Las penalizaciones por mora en el pago no se consideran intereses a efectos del presente artículo”.*

Esta es una definición suficientemente amplia como para abarcar todo lo que sería fruto de capital. A pesar de esto se pueden encontrar problemas porque no es una definición tan específica ni tan técnica.

- 1) **Créditos con garantía hipotecaria:** En algunos países se consideran bienes inmuebles, por lo que por esta vía se resolvió la disputa, quedando dentro de este artículo.
- 2) **Cláusula de participación en los beneficios del deudor:** Esto ocurre cuando los créditos se pagan con los beneficios de una determinada línea de negocios que es la que se está financiando. En Chile se agregó una reserva para eliminar esto.
- 3) **Bonos y valores públicos:** No se comprende la ganancia de capital que procede de la venta del activo.
- 4) **Subcapitalización o exceso de endeudamiento:** En este caso la normativa lo que hace es calificar deuda como capital, es decir, si la deuda excede 3 veces el patrimonio o capital. Esto está en un área gris, ya que la OCDE ofrece distintas técnicas. Cada país debe resolverlo. En Chile es un impuesto que grava al deudor, por lo que no se produce la identidad jurídica para calificarlo como doble tributación.
- 5) **Primas y Premios pagados por el deudor:** Incluidas.
- 6) **Derivados sobre tasa de interés (swap):** La OCDE dice que los pagos en estos casos no están cubiertos por este artículo, sino que se tendrá que ir a beneficios empresariales o a otras rentas, o según la ley nacional.

**1.5. Párrafo 4:** *“Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los intereses, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que proceden los intereses, una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, y si el crédito que genera los intereses está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7”.*

El crédito debe verse reflejado en un activo del establecimiento permanente y debe ser soportado directamente por el mismo. Se hace remisión al **Art. 7 CDTI** porque mediante él se debe determinar cuál es el beneficio empresarial atribuible al Establecimiento Permanente.

**1.6. Párrafo 5:** *“Los intereses se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor sea un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando el deudor de los intereses, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un Estado contratante un establecimiento permanente en relación con el cual se haya contraído la deuda por la que se pagan los intereses, y estos últimos son soportados por el citado establecimiento permanente, dichos intereses se considerarán procedentes del Estado contratante en que esté situado el susodicho establecimiento permanente”.*

Si el Establecimiento Permanente no tiene actividad no tendrá renta pasiva.

- 1) El Estado de la fuente de la renta es el Estado de residencia del deudor.**
- 2) Excepción: Crédito contratado para una Empresa Permanente y esta soporta los intereses.**

Se genera un problema cuando el deudor y acreedor son residentes de Estados contratantes, pero el Establecimiento Permanente está en un tercer Estado. Esto se resuelve según leyes internas.

**1.7. Párrafo 6:** *“Cuando en razón de las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuenta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio”.*

Esta es una norma de control que dice que, si el interés excede el de mercado, solo se aplicará por la parte de los intereses de mercado el articulado. El exceso se regirá por las normas internas del Estado, pero tomando en consideración las demás disposiciones del presente CDTI.

Esto también se puede aplicar en el exceso de endeudamiento, donde si bien el interés es en sí mismo de mercado, el crédito puede darse solo por las relaciones especiales entre el acreedor y el deudor.

- 1) Relaciones Especiales:** Propiedad directa o indirecta y parentesco.
- 2) Este caso no permite recalificación de los créditos:** El crédito por lo que no está en exceso se considera como tal y el interés tributa como interés.

## **1.8. Reservas de Chile:**

- 1) Limitación a la tasa del impuesto de retención en fuente:** Chile reservó que puede aplicar la tasa que quiera.
- 2) Concepto de interés:** En los créditos con cláusula de participación en los beneficios del deudor.

**1.9. Cláusula de Limitación de Beneficios (Párrafo 8 introducido por Chile):** *“Las disposiciones del presente Artículo no se aplicarán si el principal propósito o uno de los principales propósitos de cualquier persona vinculada con la creación o la atribución del crédito en relación al cual los intereses son pagados, fuera el de sacar ventajas de este Artículo mediante tal creación o atribución”*. Esto busca evitar el treaty shopping.

**1.10. Situación del Exceso de Endeudamiento (Oficio 813/2014 del CDTI Chile-Canadá):** En la hipótesis un deudor chileno tenía un acreedor canadiense con un 4%, pero al estar en una situación de exceso de endeudamiento debiera irse al 35%, pero como con Canadá la tasa es de 15%, se pagará la diferencia del 11%.

El SII considera que lo que se hace es que el impuesto en exceso de endeudamiento es un impuesto a los intereses, donde la base imponible se calcula de forma distinta. En este sentido no rige el CDTI.

**2. Las Regalías (Art. 12 CDTI):** La tasa general es del 30%, pero se aplica en ciertos casos una tasa rebajada del 15% en conjuntos de propiedad intelectual, programas computacionales, etc. Se vuelve a la tasa general cuando se tiene un acreedor en un país con una menor tasa y cuando entre el acreedor y el deudor de la regalía hay una relación patrimonial.

**2.1. Párrafo 1:** *“Las rentas provenientes de un Estado contratante y cuyo beneficiario efectivo es un residente del otro Estado contratante solo pueden someterse a imposición en ese otro Estado”*. Algunas de sus características más importantes son:

- 1) **Se establece tributación exclusiva en el país de residencia del acreedor:** Sin embargo, Chile siempre se reserva un derecho a gravar la regalía en el país de la fuente mediante un impuesto de retención.

En este contexto, el **Art. 12, párrafos 1 y 2 CDTI** firmado por Chile señala que: *“1. Las regalías procedentes de un Estado contratante y pagadas a un residente del otro Estado Contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.*

*2. Sin embargo, estas regalías pueden también someterse a imposición en el Estado Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este Estado, pero si el beneficiario efectivo es residente del otro Estado Contratante, el impuesto así exigido no puede exceder del 10% del importe bruto de las regalías”*.

En este contexto, nuestro país suele establecer tasas que van desde el 10% al 15% y siempre que el deudor se encuentre domiciliado o residente en Chile.

Incluso, en muchos de los CDTI firmados por Chile se ha establecido una norma especial referente a gravar con un 5% o un 10% las regalías por el uso de equipos industriales, comerciales y científicos.

- 2) **Se exige que el residente sea beneficiario efectivo de la regalía:** En esto se aplica la norma de existencia de mandatos o sociedades instrumentales que no tienen la facultad de disponer de la renta que se paga por el efecto de regalías.
- 3) **Situaciones de doble tributación:** La OCDE ha señalado que este artículo no condiciona la tributación en fuente a la tributación en residencia, siendo los países los llamados a introducir una observación en ese sentido, o bien introducirla como una limitante al uso del crédito.

- 4) **Situación de residentes sociedades pasivas:** Se dio en el caso Starbucks donde una sociedad cobraba una regalía a las sociedades operativas. La OCDE no se ha hecho cargo de estas situaciones, la cuales si bien tienen la propiedad intelectual de la sociedad, no generan ningún otro ingreso más que el cobro de la regalía en un país de baja o nula tributación.

**2.2. Párrafo 2: Definición de Regalía:** *“Cantidades de cualquier clase pagadas por el uso, o la concesión de uso, de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, de patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas”*. Algunas características interesantes son:

1) **Comprende:**

- a. **Pagos por el uso de bienes intangibles o por información:** Esto es importante ya que el concepto de regalía no cubre, por tanto, la cesión de dicho intangible o información, solo su uso.
- b. **La propiedad literaria y artística, la propiedad intelectual y los *know how*.**
- c. **No se exige que la propiedad intelectual esté inscrita o sea de aquellas que requieren inscripción para poder ser considerada para la regalía.**
- d. **Pagos por el uso indebido, falsificación o uso abusivo:** Si, a través del juicio, se dictamina un pago por dicho uso, este queda cubierto por el **Art. 12 CDTI**.

2) **No comprende:**

- a. **Enajenación de la regalía:** Esto cabe más bien dentro del **Art. 7 CDTI** sobre beneficios empresariales o en ganancias de capital.
- b. **El arrendamiento de equipos industriales, comerciales o cinéticos:** Esto se incluía en el modelo de 1977, lo cual se mantiene en muchos CDTI celebrados por Chile dentro del concepto de regalías o en su defecto, dentro de los intereses. El único que parece no contener este concepto es el CDTI con México.

Lo interesante de este caso es que en los pagos por arrendamiento y leasing hay una presunción de renta del 5% de la cuota, por lo que la tasa efectiva será de un 1,75% sobre el total.

- 3) **El caso especial del uso exclusivo y el distribuidor exclusivo:** Mientras el primero si cabe dentro del concepto de regalía porque se entrega el uso exclusivo de determinada propiedad intelectual o industrial, el caso del distribuidor exclusivo no estaría cubierto por la regalía porque se entrega la exclusividad en la distribución, no en el uso de la propiedad.
- 4) **Concepto de “Pagadas”:** El impuesto adicional se devenga por varias circunstancias, no solo por el pago, por lo que es importante determinar qué pagos quedan bajo este CDTI, determinar el momento de la determinación del gasto, etc.
- 5) **Situaciones Especiales: Roaming, Transmisión Eléctrica, Ductos de Gas y Licencias de Espectro:** Estas son cuatro hipótesis en las cuales en realidad no hay una regalía, sino que es un pago por uso de equipamiento o de un servicio, quedando subsumidos en esa relación que subyace a este pago.

- 6) **Diferencia entre el Contrato de Prestación de Servicios y las Regalías:** Muchas veces el *know how* se suele confundir con la prestación de servicios, ya que lo que se entrega no es solo el conocimiento con un valor económico, sino que lo que se necesita es que dicho conocimiento se aplique y con él se desarrolle un activo distinto. Por ello el *know how* no es una mera entrega de conocimientos, sino que va acompañada de una asesoría técnica que permita al cliente sacarle provecho a dicho *know how*. Ahora bien, hay que distinguir una serie de situaciones:
- a. **Entrega de información industrial, comercial o científica proveniente de experiencias previas:** Esta es una regalía propiamente tal, ya que no se contrata a un ingeniero para que ayude en el diseño de un puente, solo se paga por información.
  - b. **Entrega de información que no se ha patentado y no cae dentro de otras categorías:** Esto también cabe dentro de la regalía.
  - c. **Entrega de información nueva:** Obedece más bien a una prestación de servicios o asesoría técnica, más que a una regalía.
  - d. **Entrega de información para su utilización por terceros:** Hay que distinguir una serie de situaciones:
    - i. **No requiere el desarrollo de una actividad donde sean relevantes los conocimientos o experiencia:** De cierta forma, se pone este conocimiento a disposición del que está pagando por este, pero no supone el desarrollo de una actividad por parte de quien suministra esa información. En caso contrario se estaría en una especie de contrato mixto.
    - ii. **Situación del listado potencial de clientes:** Las empresas pueden tener una base de datos con sus clientes. En estos casos hay que distinguir:
      - 1. **Si el listado se elabora con información pública:** No estamos frente a un *know how*, ya que no apela a la experiencia o a base de datos privados, y como no hay propiedad intelectual esto más bien cae dentro de beneficios empresariales.
      - 2. **Si el listado se elabora con información privada:** En este caso si estamos frente a un *know how* propiamente tal, quedando bajo el concepto de regalía.
  - e. **El Contrato Mixto (Know How y Asesoría Técnica):** En este caso hay un pago por la explotación de una marca, el cual quedaría cubierto por el concepto de regalía, pero hay también una asesoría técnica en su explotación. En estos casos hay que separar el contrato y se debe analizar cuál es la parte que corresponde al *know how* y cual corresponde a la asistencia técnica o asesoría. Si el principal corresponde al *know how*, el contrato será una regalía y si el principal es la asesoría técnica, el contrato no quedaría cubierto por la regalía.
- 7) **El caso del Software Computacional:** Este cabe dentro del concepto de regalía. Sus principales características son:
- a. **Es un concepto amplio que puede abarcar:**
    - i. **Los software de aplicación como los operacionales:** Da lo mismo si es un software físico, por internet u objeto de una reventa.

**ii. Transferencia por cualquier medio.**

**iii. Software standard como software fabricados a la medida.**

- b. Naturaleza de los derechos que adquiere el beneficiario para su uso y explotación:** Se mezcla lo que es una licencia, un beneficio y lo que tributaria también por un beneficio empresarial. Lo que se da es el uso o concesión de uso, sino no estaríamos frente a una regalía.
- c. Derecho de utilización del programa que de otra forma constituiría una violación a la ley:** Si se utiliza de otro modo distinto de aquel pactado estaremos frente a una violación de la ley de propiedad intelectual.
- d. Dificultades con la necesidad que se clasifiquen como obras literarias, científicas o artísticas:** Muchas veces es difícil ubicar un software dentro de estas categorías. En algunos países lisa y llanamente se incorpora el software por disposición legal en una de estas características. En otros casos son los mismos países los que en la definición de regalía hacen una mención expresa de los software que caen dentro del concepto de regalía.
- e. Casos Especiales:**
  - i. Licencias de Empresas:** De modo que todos los usuarios de una empresa lo puedan usar, como comprar licencias para todas las filiales o personas. El pago que se hace por este derecho a duplicar o triplicar no se incorpora dentro del concepto de regalía, sino que se incorpora al concepto de beneficio empresarial porque se estaría pagando por reproducir la licencia, no por la licencia en sí misma.
  - ii. Derechos de Distribución de Software:** En este caso no se paga por el uso del software, sino que se paga por distribuir el software, es decir, se paga por los derechos comerciales y de explotación de este.
  - iii. Ideas, Principios y Fórmulas subyacentes a un Software:** A veces puede ocurrir que un software sea muy específico, por lo que la entrega de su uso puede ir incorporado dentro de un *know how*. En estos casos el software está incluido dentro del *know how*.
  - iv. Pagos por la Propiedad Plena de un Software (Modalidad Geográfica o Temporal):** Esto se relaciona con los software a la medida, donde hay una delgada línea entre beneficio empresarial y regalía, ya que si se encarga un software y luego se hace dueño de dicho software estaremos más bien en un beneficio empresarial y no en una regalía.
  - v. Acuerdos Mixtos:** Puede haber un software con una asesoría técnica conectada, como un periodo de *training*, la *hotline* para efectos de asesoría, etc. Acá habrá que ver cuál es el contrato principal.

**2.3. Párrafo 3:** *“Las disposiciones del apartado 1 no son aplicables si el beneficiario efectivo de las regalías, residente de un Estado contratante, realiza en el Estado contratante del que proceden las regalías una actividad empresarial por medio de un establecimiento permanente situado allí, y si el bien o el derecho por el que se pagan las regalías está vinculado efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7”.*

En este caso el acreedor de la regalía es un residente extranjero, pero posee en el país de la fuente de la renta un establecimiento permanente. Este caso se escapa del concepto de regalía y tributa como beneficio empresarial, siempre que se den los siguientes elementos:

- 1) **El acreedor de la regalía debe ser un domiciliado o residente en un Estado contratante.**
- 2) **El acreedor de la regalía debe realizar todo parte de su actividad en el Estado del deudor a través de un establecimiento permanente ubicado en dicho Estado.**
- 3) **El bien o el derecho por el que se pagan las regalías debe estar vinculado efectivamente al establecimiento permanente:** No basta la mera contabilización del intangible en otro Estado, debe efectivamente desarrollarse por el establecimiento permanente.

La razón de que no se aplique el concepto de regalía está en que finalmente la renta es obtenida por un residente del mismo Estado de residencia del deudor.

**2.4. Párrafo Especial del Establecimiento Permanente del Deudor:** *“Las regalías se consideran procedentes de un Estado contratante cuando el deudor es un residente de ese Estado. Sin embargo, cuando quien paga las regalías, sea o no residente de un Estado contratante, tenga en un estado contratante un establecimiento permanente o una base fija que soporte la carga de las mismas, estas se considerarán procedentes del Estado donde esté situado el establecimiento permanente o la base fija”.* Esto es propio de los modelos chilenos, por lo que no está incluido en el Modelo CDTI de la OCDE. Sus principales características son:

- 1) **No es necesario que el establecimiento permanente sea parte del contrato, sino que debe soportarlo económicamente:** En este contexto, puede ser una norma de inclusión o exclusión, pudiendo tener residencia en uno de los Estados contratantes o no.
- 2) **Estando situado el establecimiento permanente en Chile se entiende que se aplica el CDTI:** Esto porque lo que interesa es quien soporte el pago de la regalía.

**2.5. Párrafo 4:** *“Cuando, por las relaciones especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o por las que uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente Convenio”.*

Esta es una norma de control muy similar a la aplicable a los intereses, donde por la relación existente entre el acreedor y el deudor se puede presumir que se realizó un pago excesivo, no quedando cubierto el exceso. En tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a la legislación interna de cada Estado. Sin embargo, se reconoce el carácter de regalía sobre el monto que no se pagó en exceso.

**2.6. Párrafo de Limitación a los Beneficios:** *“Las disposiciones de este Artículo no se aplicarán si el propósito principal o uno de los principales propósitos de cualquier persona relacionada con la creación o atribución de derechos en relación a los cuales las regalías se paguen fuera el de sacar ventajas de este Artículo mediante tal creación o atribución”.*

Es una medida de control para evitar el *treaty shopping*. El problema es que su redacción es muy amplia, por lo que la autoridad tributaria suele resolver la situación a través de los gastos, ya sea porque son excesivos o tienen ausencia de timbre. En Chile se utiliza esta vía.

**2.7. Tratamiento del Gasto en Regalías:** El **Art. 31 N°12 LIR** establece una restricción del gasto al 4% de los ingresos por venta o servicios a título de regalía. Para ello se debe contrastar el pago de la regalía contra los ingresos del giro, y si excede del 4% de los ingresos del giro, se estará sobre lo que la ley permite rebajar como gasto. Esto tiene dos excepciones:

- 1) Cuando no exista una relación entre el acreedor y el deudor.**
- 2) Cuando la tasa que el país de residencia exija por el beneficio sea igual o superior al 30%.**

Estos gastos deben ser rebajados al momento en que se hayan percibido, siempre y cuando se haya acreditado el pago del impuesto adicional (**Art. 31, inc. 1 LIR**).

Esto último sería discriminatorio, ya que si el acreedor estuviera en Chile se podría deducir como gasto la regalía con su mera contabilización. De ahí que, si el CDTI tuviera una Cláusula de No Discriminación, primaria el CDTI por sobre la norma interna.

### **3. Dividendos (Art. 10 CDTI):**

**3.1. Párrafo 1:** *“Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado contratante a un residente del otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado”.*

- 1) Los dividendos tienen un régimen tributario compartido en residencia y fuente:** Se permite que exista tributación tanto en fuente como en residencia.
- 2) Concepto de “Pagados” se utiliza en sentido amplio:** En Chile hay que relacionarlo con el impuesto adicional con las hipótesis de devengamiento, retención y pago.

**3.2. Párrafo 2:** *“Sin embargo, dichos dividendos pueden someterse también a imposición en el Estado contratante en que resida la sociedad que paga los dividendos y según la legislación de ese Estado; pero, si el beneficiario efectivo de los dividendos es un residente del otro Estado contratante, el impuesto así exigido no podrá exceder del:*

- a) 5% del importe bruto de los dividendos si el beneficiario efectivo es una sociedad (excluidas las sociedades de personas –partnerships–) que posea directamente al menos el 25% del capital de la sociedad que paga los dividendos;*
- b) 15% del importe bruto de los dividendos en los demás casos.*

*Las autoridades competentes de los Estados contratantes establecerán de mutuo acuerdo las modalidades de aplicación de estos límites. Este apartado no afecta a la imposición de la sociedad respecto de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos”.*

Esto implica que los dividendos pueden someterse a imposición en el país en que se pagan los dividendos, pero con limitaciones, ya que el impuesto será como máximo de un 5% para sociedades que posean al menos un 25% del capital de la sociedad que paga los dividendos y de máximo un 15% para el resto de los casos.

Sin perjuicio de ello, el ultimo inciso de este párrafo señala que esto no afecta al impuesto corporativo, el cual no tiene limitación alguna.

Ahora bien, es importante que si la sociedad es transparente no son residentes ni beneficiarios del CDTI, entendiéndose que la desarrollan los socios detrás, por lo que más bien se aplica el **Art. 7 CDTI** sobre beneficios empresariales.

**3.3. La Cláusula Chile:** *“Las disposiciones de este párrafo no limitarán la aplicación del impuesto adicional a pagar en Chile en la medida que el impuesto de primera categoría sea deducible contra el impuesto adicional”.*

Esta cláusula se encuentra en todos los CDTI que tiene Chile con esta misma estructura y permite que Chile se asegure el pago de todo el impuesto adicional. Pareciera que de la redacción basta que la legislación permita usar esto como crédito, y no exige que en el caso concreto se haya pagado y sea un crédito efectivo contra el impuesto adicional.

**3.4. Párrafo 3: Concepto de Dividendo:** *“El término “dividendos”, en el sentido de este artículo, significa las rentas de las acciones, de las acciones o bonos de disfrute, de las participaciones mineras, de las partes de fundador u otros derechos, excepto los de crédito, que permitan participar en los beneficios, así como las rentas de otras participaciones sociales sujetas al mismo régimen fiscal que las rentas de las acciones por la legislación del Estado de residencia de la sociedad que hace la distribución”.*

- 1) **Es un concepto amplio, pero no comprende los *partnerships*:** Se busca incorporar el pago de cualquier beneficio o renta asociada a la participación en el capital de un vehículo legal. No incluye los *partnerships* porque son sociedades transparentes.
- 2) **Imposibilidad de generar un concepto independiente del derecho interno:** Por ello el concepto de dividendo no dice mucho, se remite al derecho interno.
- 3) **Situaciones Excepcionales: *Thin Capitalization Rule* / *Debentures*:** No tiene mucha aplicación en Chile, ya que no existe una norma que presuma que el exceso de endeudamiento sea dividendo. Es un impuesto que se aplica sobre el deudor.

En relación a los *debentures* o bonos convertibles a acciones, mientras no se conviertan serán dividendos, por lo que deberán seguir tributando los intereses y acciones como tales.

- 4) **Dividendos sobre Utilidades y su diferencia con la Devolución de Capital:** El dividendo es el pago que se hace sobre utilidades que obtiene la empresa, y no aplica esto en el caso de devolución de capital, los cuales suelen estar libres de tributación.

**3.5. Párrafo 4:** *“Las disposiciones de los apartados 1 y 2 no son aplicables si el beneficiario efectivo de los dividendos, residente de un Estado contratante, realiza en el otro Estado contratante, del que es residente la sociedad que paga los dividendos, una actividad empresarial a través de un establecimiento permanente situado allí y la participación que genera los dividendos está vinculada efectivamente a dicho establecimiento permanente. En tal caso son aplicables las disposiciones del artículo 7”.*

Esto es parte de la fuerza de atracción de los Establecimientos Permanentes, generando una norma anti abuso, ya que si la actividad ha sido desarrollada por este y existe una conexión efectiva es aplicable el **Art. 7 CDTI** sobre beneficios empresariales.

**3.6. Párrafo 5:** *“Cuando una sociedad residente de un Estado contratante obtenga beneficios o rentas procedentes del otro Estado contratante, ese otro Estado no podrá exigir impuesto alguno sobre los dividendos pagados por la sociedad, salvo en la medida en que esos dividendos se paguen a un residente de ese otro Estado o la participación que genera los dividendos esté vinculada efectivamente a un establecimiento permanente situado en ese otro Estado, ni tampoco someter los beneficios no distribuidos de la sociedad a un impuesto sobre las mismas, aunque los dividendos pagados o los beneficios no distribuidos consistan, total o parcialmente, en beneficios o rentas procedentes de ese otro Estado”.*

- 1) **Limitaciones a la Extraterritorialidad de Impuestos sobre los Dividendos:** Esta es una situación que en Chile no se da, apuntando a una empresa que desarrolla actividades en otro Estado, generando una renta y esta la percibe y obtiene la sociedad chilena y luego se acuerda un dividendo con cargo a esta renta de origen de fuente peruana. Hay Estados que pueden imponer un impuesto sobre el impuesto porque las utilidades con cargo a los cuales se paga este dividendo es de fuente peruana. Con esta norma se busca evitar que el esfuerzo de la OCDE quede sin efecto por estas normas.
- 2) **Situación de los CFC:** La OCDE dice que la hipótesis de este párrafo de dividendo es distinta de los CFC, ya que aplica impuestos sobre accionistas o socios de la sociedad. El párrafo 5 apunta a un impuesto sobre la sociedad por la utilidad no distribuida, teniendo un contexto distinto la norma de los CFC.

### EL CASO EMBONOR

**1. Hechos:** Una empresa domiciliada en Arica llamada Coca Cola Embonor S.A. amplió su negocio de distribución y embotellado, adquiriendo acciones de embotelladores WB S.A. Esto se materializó en cinco etapas principales.

Primero se formó una agencia en Islas Caimán y se constituyó una filial EAO. La agencia hizo un aporte de capital a EAO con recursos que obtuvo de la emisión de un bono de un sindicado de bancos. En virtud del **Art. 41 B LIR** en relación con el **Art. 12 LIR** los resultados de la agencia se transmiten directamente a la sociedad domiciliada o residente en Chile, lo que permitía rebajar como gasto los intereses de dicho bono. Luego, Embonor, a través de la agencia, refinanció el bono mediante un crédito sindicado por 180 millones, pero todas esas operaciones siguieron devengando intereses, los que repercutían directamente en la matriz. Después se renegoció el crédito para obtener más plazo.

En una segunda etapa EAO compra las sociedades operativas de embotelladores WB S.A., comprando la totalidad de las acciones de ILABSA e INCHCAPE por 613 millones de dólares. La importancia de ILABSA es que era dueña de las sociedades operativas ubicadas en Chile. En esta época no existía la venta indirecta, por lo que no era renta de fuente chilena.

En una tercera etapa una filial de Coca Cola Embonor, ubicada en Chile, la cual se llamaba Embonor compra a EAO todas sus acciones en ILABSA por 745 millones de dólares, dinero que quedo debiendo, lo cual genera una cuenta por cobrar para EAO y una cuenta por pagar para Embonor. Esto genera 132 millones de dólares de utilidad en EAO, la cuales quedan sin tributación por encontrarse EAO en Islas Caimán.

En una cuarta etapa Embonor S.A. se divide en dos sociedades, una encargada del transporte y otra con los activos del área de producción. En esta división se le dio a Nueva Embonor la cuenta por pagar para EAO.

En una quinta etapa Coca Cola Embonor S.A. absorbió a Embonor S.A. Producto de esta fusión Coca Cola Embonor S.A. queda como propietario de EAO. En virtud de lo anterior EAO jamás cobraría la deuda a Nueva Embonor.

**2. Situación Tributaria:** En primer lugar, los resultados de la agencia desde el 2000 fueron pérdidas, lo que implicaba que como eran la misma persona jurídica, Coca Cola Embonor S.A. reportara pérdidas. Ante ello Coca Cola Embonor S.A. hizo uso del PPUA y el carry back que permitía la legislación vigente en la época por las pérdidas generadas en la agencia. Frente a ello el SII practica una citación por considerar que el gasto producido por el interés en la agencia no tenía correlato con la generación de una renta gravada en el mismo ejercicio por parte de la matriz, produciéndose una reliquidación del impuesto.

Frente a la reliquidación practicada por el SII, Coca Cola Embonor S.A. reclamó y sostuvo que:

- 1) Los gastos se habían efectuado para generar renta gravada, ya que se usaron para adquirir bienes que le permitían a Embonor desarrollar su giro en teoría, no procediendo la distinción entre una matriz y una agencia. Ante ello el SII contestó que los antecedentes entregados no eran suficientes para acreditar la constitución de la agencia, por lo que se cuestionó su existencia.
- 2) El aporte de capital era susceptible de generar ingresos gravados en Chile, ya que cualquier distribución que EAO haga a su agencia o que la agencia perciba de esta estaría gravada. El SII contesto que nunca se distribuyeron dividendos y que tras un tiempo las acciones de ILABSA fueron vendidas, por lo que EAO no podría generar ingresos. Además, la utilidad por la venta se había dejado en Islas Caimán.
- 3) En la deducibilidad de intereses la generación de rentas es potencial y nunca necesaria a todo evento, citando un oficio sobre intereses pagados para adquirir acciones de S.A.

**3. Resolución del TTA de Arica:** En esta sentencia se esperaba que el tribunal simplemente se refiriera a si los intereses eran necesarios o no para producir la renta, pero va mas allá.

En primer lugar, el TTA reconoce que debe acreditarse en forma especial y especifica la renta generada por dichos bienes para que proceda la deducción como gasto de los intereses. En este contexto no se acepta el criterio del contribuyente de que los gastos tienen que ser susceptibles para generar la renta gravada.

En segundo lugar, el TTA, a diferencia del SII, si reconoce la existencia de la agencia, de modo que establece como hecho no discutido su existencia y que con los recursos que obtuvo adquirió acciones. Se razona que la agencia solo ha remitido pérdidas a su casa matriz, y que no se ha demostrado la relación entre los gastos y los intereses de la matriz afectos a primera categoría.

En tercer lugar, considera que la que hizo la inversión en el extranjero fue EAO y no la agencia, y que Coca Cola Embonor S.A. solo reconocería ingresos en Chile en la medida que dicha empresa efectúa efectivamente distribuciones a la agencia. Pero esto nunca iba a ocurrir ya que esto era una máquina para generar pérdidas.

En cuarto lugar, el tribunal razona respecto de la compra de las acciones de ILABSA a Embonor y la cuenta por pagar de esta, donde se dice que hay un crédito directo, con una utilidad del 18% dejando la utilidad en el extranjero. Es decir, se reconoce la planificación tributaria destinada a pagar menos impuestos en Chile. Además, dice que Embonor no tenía dinero en Chile para esto, pero al ser el vendedor una sociedad relacionada esto no importaba, ya que esta cantidad nunca se iba a pagar.

El tribunal se refiere al sentido que tiene que la agencia haya realizado toda esta operación para que un tercer adquiriera la sociedad operativa, cuando habría sido más fácil que una comprara directamente la agencia en el extranjero. Se concluye de esto que no hay causa, aunque en realidad esta es pagar menos impuestos, lo cual resulta muy criticable, ya que, si bien no existía la norma anti elusión, el tribunal llego a algo parecido.

El tribunal concluye que al tratarse de costos artificiales no corresponde a aquellos necesarios para producir la renta, indicando que no hay una “*legítima razón de negocios*”, concepto que saca del **Art. 64 CT** que habla de los casos en que no se pueden tasar los aportes de un empresario individual u otra sociedad a otra sociedad.

La norma anti elusión está motivada por casos como este, donde la sentencia no se dedica a ver si era o no un gasto necesario, sino que se da el gusto de reconocer esta planificación agresiva y castigarlo por esto.

## MEDIDAS INTERNACIONALES PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Uno de los temas más importantes actualmente tiene que ver con el intercambio de información entre los distintos países. En este contexto, nuestra ley de impuesto a la renta se ha ido adaptando a las nuevas tendencias de información, incluyendo normas de traspaso de información y normas que miran con malos ojos las inversiones en paraísos tributarios, como el **Art. 41 G LIR** que presume el control cuando dicha sociedad se encuentra domiciliada o residente en países con baja o nula tributación, para efectos de exigir impuestos sobre base devengada o percibida.

Si bien no se define que se entiende por paraíso fiscal, el **Art. 41 D LIR** contiene un listado del Ministerio de Hacienda del 2013 donde se señala una lista de países o territorios que son paraíso fiscal. Asimismo, el **Art. 41 H** contiene aspectos objetivos respecto de los cuales un territorio se puede considerar como paraíso fiscal, sin perjuicio de que se necesita de todas formas una resolución del SII.

### I. ANTECEDENTES.

**1. Medidas adoptadas internacionalmente:** Entre el 2009 y el 2010 la OCDE desarrolló su programa e instrumento de acción en torno a la idea de evitar la doble imposición internacional centrando tal objetivo en el cumplimiento de los principios tributarios incluidos en dos de sus documentos esenciales:

1) **La Guía de Precios de Transferencia (Junio 2010):** Este es un documento de buenas prácticas sobre precios de transferencia. A Chile hoy en día no le importa mucho porque el **Art. 41 E LIR** incluye todas las recomendaciones de esta guía.

2) **Modelo de CDTI.**

El 2010 se aprobó en EE.UU. el *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA) con el objeto de tomar conocimiento sobre las inversiones que sus nacionales hacían en el extranjero.

En 2012 se firma el *Intergovernmental Agreement* (IGA) entre EE.UU. y Reino Unido, Francia, España, Italia y Alemania. El IGA es la forma que tiene EE.UU. de exigirle a los países el cumplimiento o envío de información de sus nacionales. Chile firmó recientemente uno de estos con EE.UU.

El 2013 los países del G20 solicitan formalmente a la OCDE desarrollar un estándar común de intercambio de información. Adicionalmente surge el trabajo del Proyecto BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*).

El 2014 la OCDE confecciona un texto estándar común y este es depositado por los países del G20. Desde esa fecha hasta hoy 94 países se han comprometido a implementar el *Common Reporting Standard* (CRS) a 2017 – 2018. Este contiene dos instrumentos:

1) **El Estándar propiamente tal.**

2) **El MCAA o Model Competence Authority Agreement:** Que es el modelo de acuerdo bilateral de intercambio de información que puede suscribirse bajo el **Art. 6 MAAT** (*Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*).

Esto implica que Chile se compromete a mandar esta información bajo este CRS a partir de 2018.

### 2. Medidas adoptadas en el ámbito local:

**2.1. Convenios:** Los CDTI contemplan un artículo relativo al intercambio de información que estipula: “Intercambio de información recae sobre antecedentes relevantes sobre la aplicación del Convenio. La

*información recibida por un país será tratada con secreto y como si se hubiera obtenido por el país que la recibe”.*

**2.2. FATCA:** El 2014 Chile y EE.UU. firmaron un IGA basado en el Modelo 2 de implementación del FATCA. Este modelo insta a las instituciones financieras y sucursales locales a suscribir convenios con el IRS para identificar e informar respecto de tenedor de cuentas estadounidenses en Chile.

En virtud de estas normas el banco chileno está obligado a hacer un mínimo *due diligence* o estudio de las personas que abran cuentas en este para saber si son ciudadanos americanos. Además, se impone a las entidades locales que solo deben abrirle cuentas a ciudadanos americanos que expresamente accedan a que se divulgue su información al IRS.

Este IGA se encuentra suscrito pero su entrada en vigencia depende de la aprobación por parte de EE.UU. del CDTI con Chile.

**2.3. Otras Medidas:** En el marco de la reforma tributaria se introdujeron a nuestra legislación normas que van en línea con el proyecto BEPS de la OCDE y que también promueve el intercambio de información.

- 1) **Introducción de normas relativas a los CFC (Art. 41 G LIR).**
- 2) **Modificación a las normas de sobreendeudamiento (Art. 41 F LIR):** Se hizo para evitar la elusión o planificación excesiva, o pasar como intereses afectos a una tributación menor montos que corresponden a dividendos, incorporándose con el **Art. 58 N° 1 LIR** las normas de *thin capitalization rule* en 2001.
- 3) **Fortalecimiento de normas de precios de transferencia mediante la suscripción del acuerdo de autoridad competente para implementar el “Contry by Country Report”.**
- 4) **Introducción de norma general anti elusión del Art. 4 ter LIR.**

## II. MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS (MAAT).

También conocido como Convenio sobre Asistencia Administrativa en Materia Tributaria, permite a nuestro país ampliar la red de países y jurisdicciones con las cuales intercambiar información para fines tributarios, además de otorgar a nuestra autoridad tributaria otras herramientas como auditorías, asistencia en cobro de impuestos, notificación de documentos tributarios, medidas precautorias, etc. Todo esto permite a los países firmantes intercambiar información tributaria de manera automática.

En este contexto, el **Art. 6 MAAT** habla del intercambio de información, indicando que no se debe esperar que un país le solicite o envíe la información del **Art. 4 MAAT**. Asimismo, este último artículo hace referencia a formatos estándares de intercambio de información, por lo que se debe recordar el CRS que es un estándar adoptado por varios países para hacer más fácil el intercambio de información.

**1. El CRS (Common Reporting Standard):** Es un nuevo estándar de intercambio de información en materia tributaria que dispone que las instituciones financieras deben efectuar determinados procedimientos de *due diligence* respecto de cuentas mantenidas por residentes de terceros Estados en el país. Esta información debe ser posteriormente informada a la autoridad fiscal de su país, de la manera y con los procedimientos que se establecen para tales efectos.

Esto busca permitir a las autoridades tributarias de los países que lo suscriban recibir anualmente información sobre las cuentas financieras que sus contribuyentes mantengan en el ejercicio.

Ahora bien, este procedimiento de *due diligence* distingue si se trata de:

- 1) **Cuentas Nuevas abiertas desde el 1 de enero de 2017:** En este caso se debe solicitar a las instituciones financieras que apliquen dichos procedimientos a sus clientes nuevos.
- 2) **Cuentas Preexistentes de personas naturales, abiertas antes del 31 de diciembre de 2016:** Si el monto de la cuenta es inferior a US\$ 250.000 según balance, las instituciones financieras no están obligados a revisar. Si el valor de la cuenta es superior a esa cantidad las instituciones financieras deberán revisar la información que hayan recabado para cumplir con normas sobre lavado de activos y conocimiento del cliente.

**2. El Envío de Información:** El envío de la información de la entidad al SII se hace por declaración jurada. El SII adecua esa información a formato estándar CRS y envía y recibe información de autoridades extranjeras.

### III. PLAN BEPS (BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING).

Este plan ataca principalmente algunas prácticas que grandes empresas o grupos multinacionales han estado llevando a cabo, que hicieron que la OCDE se preocupara y asumiera el desafío de emitir recomendaciones en este sentido. En caso de no cumplirse con ellas se puede caer en consecuencias bajo el *peer to peer review*.

Es un catálogo de recomendaciones bastante etéreo, donde sus enunciados por parecidos unos con otros, o con ejemplos que se refieren a otra acción dentro del mismo.

**1. Motivaciones:** La globalización ha permitido el libre movimiento de capitales y trabajo, el traslado de fábricas a lugar más baratos, la eliminación de barreras al comercio y el desarrollo tecnológico y de las telecomunicaciones.

Esto hace que los sistemas tributarios de los distintos países que tienen jurisdicción sobre un mismo contribuyente o una misma renta puedan entrar en conflicto. Esto puede ser fuente de una doble no tributación, lo que trae como consecuencia:

- 1) **Un perjuicio para los gobiernos.**
- 2) **Un perjuicio para los contribuyentes a título individual:** Ya que cuando las empresas trasladan sus ingresos hacia otras jurisdicciones se debe aumentar la carga tributaria de los que sí pagan.
- 3) **Un perjuicio para la empresa:** Por una baja en su reputación, ya que la planificación tributaria es muy mal vista por las personas. En segundo lugar, puede haber una desventaja competitiva, ya que los impuestos son gastos y la empresa que no puede cambiar su domicilio para disminuir sus impuestos está en desventaja con la que sí puede. Finalmente, las empresas nacionales no pueden competir con las multinacionales porque estas ventajas indebidas.

Es precisamente esto lo que busca evitar el Plan BEPS: que las empresas multinacionales, de manera abusiva o artificial, cambien su base de negocios o distintas presencias en distintos países o en su propio país para obtener ventajas tributarias.

BEPS se parece bastante a la norma general antielusión del **Art. 4 bis y ter LIR** que pretenden que los contribuyentes en los actos, negocios o contratos que celebren tengan un sentido económico más allá de pagar menos impuestos.

### **2. Génesis del Plan BEPS:**

- 1) **Año 2012:** Los líderes del G20, reunidos en “Las Ventanas al Paraíso”, México, decidiendo solicitarle a la OCDE que recomendara qué hacer frente a la evasión y elusión de impuestos que representaba un 4% a un 10% de la renta global. En virtud de lo anterior la OCDE se embarcó en el proyecto de urgencia.
- 2) **Año 2013:** La OCDE emitió el informe previo “Lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios”.
- 3) **Año 2015:** Luego de un trabajo conjunto entre los 34 miembros de la OCDE, otros países del G20 y con economías en vías de desarrollo y grupos económicos, en octubre de 2015 la OCDE elaboró las 15 recomendaciones específicas que forman parte del proyecto BEPS. Este plan de acción:
  - a. **Identifica las acciones necesarias para paliar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios;**
  - b. **Establece plazos para poner en marcha estas acciones, y**
  - c. **Identifica los recursos necesarios y la metodología para poner en marcha estas acciones.**

Lo que busca con el plan de acción es evitar la doble exención, así como los supuestos de exención o baja imposición asociados a prácticas que **separen artificialmente los ingresos imposables de las actividades que los generaron.**

**3. Las 15 Acciones del Plan BEPS:** Estas acciones pueden resumir todas las preocupaciones.

### **3.1. Principios Generales:**

- 1) **Acción N°1:** “Abordar los retos de la economía digital para la tributación”. La OCDE se dio cuenta que el desarrollo digital se encontraba incorporado de manera profunda en la economía y en las empresas, lo que podía dar lugar a lagunas o principios de evasión. Es decir, la OCDE se dio cuenta que producto de “nuevas” tecnologías y dar servicios de manera remota se podía producir que no se pagaran los impuestos que debían. *Ejemplo: En Chile si se compra un libro a un vendedor extranjero se debiera pagar impuesto adicional, pero la reforma del 2013 generó la exención de pagos por software estándar, por lo que si se compra un libro digital este no estaría afecto a impuesto. Esto quiere evitar BEPS, aunque Chile tomó una decisión por acercar la tecnología.*
- 2) **Acción N°15:** “Desarrollar un instrumento multilateral que incorpore las otras recomendaciones establecidas en el Plan BEPS”. Esto no ha ocurrido aun, pero hoy Chile, mediante su Ministerio de Hacienda, está negociando una modificación multilateral a algunos aspectos de los CDTI, ya que estos comenzaron a quedar atrás.

**3.2. Coherencia:** La idea es que las leyes tributarias de los diferentes países funcionen de manera que cualquier ingreso caiga dentro de la legislación tributaria de a lo menos una jurisdicción tributaria y no más de una. Dentro de esto hay acciones específicas:

- 1) **Acción N°2:** “Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos”. Son mecanismos híbridos aquellos que produzcan, por ejemplo, la doble deducción (gastos en ambas jurisdicciones) o el diferimiento a largo plazo. En el contexto de esta acción se ha recomendado a los Estados:
  - a. **Modificar los CDTI basado en el Modelo OCDE para no obtenerse ventajas indebidas de los tratados.**

- b. Disposiciones en la legislación nacional que eviten la exención o falta de reconocimiento de ingresos por pagos deducibles para el pagador:** En el **Art. 31, inc. 4 N°1 LIR** en relación con el **Art. 59 LIR** se regulan los gastos, y en este caso particular se refiere a los intereses, que se pueden deducir como gastos cuando se encuentra pagados o adeudados. Esto permitía una situación muy especial, ya que si se tenía un interés pactado con una entidad en el extranjero se podía deducir como gasto dicho interés al momento de ser adeudado, pero solo se debía pagar el impuesto adicional cuando efectivamente se pagara el interés. Entonces la sociedad chilena tenía un interés devengado y no pagado que usaba como gasto. Esto se limitó con la reforma que solo permite deducir como gasto el interés cuando se encuentre efectivamente pagado.
  - c. Evitar en las legislaciones internas la deducción de pagos que también resulten deducibles en otra jurisdicción.**
- 2) **Acción N°3:** Consiste en un refuerzo a la normativa sobre CFC.
  - 3) **Acción N°4:** *“Limitar la erosión de la base imponible por vía de deducciones en el interés y otros pagos financieros”*. Aquí se empieza a notar que muchas acciones del Plan BEPS se topan unas con otras, como esta con la Acción N°2.
  - 4) **Acción N°5:** *“Combatir las prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia”*. Se trata de una declaración de principios para las disposiciones internas que dicten los Estados. Esto se puede notar en Chile con Norma General Anti elusión.

**3.3. Sustancia:** La idea es que la renta sea afectada con impuesto en el lugar donde la persona responsable de crear dicha renta desarrolle su actividad. Esto dice relación con el tema del abuso de convenios y de las jurisdicciones, de establecer unidades de negocios o filiales con el exclusivo objeto de aprovecharse de una situación tributaria más ventajosa o artificialmente más ventajosa.

- 1) **Acción N°6:** *“Prevenir la utilización abusiva de los convenios”*. En este contexto la definición de Establecimiento Permanente debe ser revisada para impedir abusos, porque la existencia de un Establecimiento Permanente implica que los beneficios del convenio se anulan.
- 2) **Acción N°7:** *“Impedir la elusión artificiosa del estatuto del establecimiento permanente”*.
- 3) **Acción N°8, 9 y 10:** *“Asegurar que los resultados de los precios de transferencia se encuentren en línea con la creación del valor”*. Esto incluye:
  - a. Los intangibles (N°8).**
  - b. El riesgo y capital (N°9):** Como ocurre cuando se asignan participaciones excesivas solo por haber asumido contractualmente riesgos o haber aportado capital.
  - c. Otras transacciones de alto riesgo (N°10).**

Esto es lo que se conoce como *profit shifting*, ya que lo que ocurría es que el país A vendía al país B una mercancía sin generar un mayor valor, y luego este, que tiene un tratamiento tributario preferente, vendía a un país C.

**3.4. Transparencia:** La idea es que todas las autoridades tributarias tengan datos e información sobre las actividades globales de los contribuyentes, de manera que sea posible determinar si efectivamente están pagando “lo justo” en una determinada jurisdicción.

- 1) **Acción N°11:** “*Establecer metodologías para la recopilación y el análisis de datos sobre la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios, y sobre las acciones para enfrentarse a ella*”. Como desarrollar indicadores para medir la magnitud e impacto económico de ciertas conductas o actitudes.
- 2) **Acción N°12:** “*Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos de planificación fiscal agresiva*”. En esta recomendación se incluyen el diseño de normas de declaración obligatoria para transacciones o estructuras agresivas o abusivas, como la de precios de transferencia.
- 3) **Acción N°13:** “*Reexaminar la documentación sobre precios de transferencia, de manera de aumentar la transparencia en la administración tributaria*”. El **Art. 14 LIR** establece una sanción cuando no se cumple con la obligación de transparentar los precios de transferencia en la declaración jurada. La Circular N°31 de 2006 señala cuáles son dichas sanciones y lo hace en relación con los esfuerzos desarrollados por los países miembros de la OCDE y el G20 con el plan BEPS.
- 4) **Acción N°14:** “*Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de controversias*”. Esto principalmente incluye desarrollar soluciones para luchar contra los obstáculos que impiden que los países resuelvan las controversias relacionadas con los convenios mediante procedimientos amistosos.

**4. Implementación de las Medidas:** Depende del tipo de acciones, pero en general puede darse tres tipos de implementación:

- 1) **Modificación de disposiciones legales internas:** Esto se ha hecho en Chile con la reforma tributaria.
- 2) **Cambios en los Comentarios al Modelo CDTI de la OCDE.**
- 3) **Cambios en el mismo Modelo CDTI de la OCDE:** En este contexto se hace relevante la posibilidad de modificarlos multilateralmente.

Por último, se hará una invitación a los países del G20 que no son miembros de la OCDE, así como a países en desarrollo, para que adopten las medidas del Plan BEPS.

**5. El Plan BEPS en Chile:** Se ha avanzado en la incorporación de recomendaciones y últimas tendencias en materia de tributación (como normas de precios de transferencia, CFC, etc.).

Adicionalmente, en cumplimiento de la Acción N°6 (prevención del abuso de los convenios de doble tributación), el SII emitió la Resolución N°48 de 2015, modificada por la Resolución N°1 de 2016.

Pero en realidad el **Art. 74 N°4, inc. 11 LIR** ya había sido modificado en el 2013. Si el pagador esta beneficiado por un convenio no había mucho sentido en que se haga la retención y el pago y luego se pida la devolución si el contribuyente sabe que el acreedor esta domiciliado en el extranjero y había un CDTI que dejaba la tasa en 0.

A partir del 1 de enero de 2013 se modificó dicho artículo para que aquellos que cayeran en este caso pudieran no hacer la retención si se dan los siguientes requisitos:

- 1) **Que el contribuyente domiciliado o residente en el extranjero acredite su residencia,**
- 2) **La declaración jurada que el contribuyente extranjero no tiene un establecimiento permanente o base fija en Chile a la cual atribuirle dichas rentas y**

- 3) **Que esa persona sea beneficiario efectivo del país:** Aquí entra la resolución N°48 que establece una declaración jurada que tiene que llenar el contribuyente domiciliado o residente en el extranjero en que tiene que jurar que no tiene Establecimiento Permanente en Chile.